

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

I. Consistiendo la prestación en la entrega de una cosa genérica*, el deudor no puede nunca, en principio, alegar imposibilidad fáctica para cumplir la obligación, ya que en ésta *genera non pereunt* (los géneros no perecen).

- * Así, si tengo que pagar 100 sestercios, no puedo alegar que aquellos que hubiera destinado al pago los he perdido o me los han robado: tengo la obligación de conseguir otros.

II. En cambio, cuando la prestación consiste en la entrega de una cosa específicamente determinada, el deudor puede evitar la responsabilidad obligacional alegando que la cosa ha perecido por caso fortuito o fuerza mayor. Responde, en cambio, por los otros dos únicos supuestos posibles de inejecución, que son el dolo y la culpa.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende que hay caso fortuito o fuerza mayor cuando ocurre un acontecimiento no previsto por el deudor; o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado.

- * Así, por ejemplo, no puedo entregar el esclavo Stichus porque se enfermó súbitamente y murió; o el edificio, porque se incendió; o las mercaderías, porque me fueron arrebatadas por actos violentos de terceros.
- * Se suele distinguir entre el "caso fortuito" —como hecho imprevisto— y la "fuerza mayor" —hecho que aun previsto no ha podido evitarse.
- * En estos casos el deudor queda liberado de responsabilidad siempre que no haya sido por su falta que se provocó la destrucción de la cosa. Pero habría falta si habiéndoselo prestado un objeto —comodato—, lo expone a una situación riesgosa: lleva una vajilla de plata prestada a un barco para cenar allí y el oleaje se la arrebató; o lleva a la guerra el caballo que debía entregar al acreedor.

En ciertos casos, algunos deudores, sea por una convención expresa, sea por haberlo determinado el mismo derecho, quedan responsabilizados por lo que se dio en llamar la custodia.

Es el caso del sastre que ha recibido una prenda para arreglarla; o el del tintorero, para teñirla. También rige para el comodatario.

Esto representaba una agravación de los deberes del ciudadano, teniendo que responder los deudores muchas veces por un caso fortuito, como la fuga de un esclavo que debía cuidar, o el hurto del objeto debido. Para excusarse debían concurrir clarísimas situaciones de fuerza mayor, como ser un incendio, una inundación o un terremoto.

- * Esta responsabilidad por la *custodia* abarca, pues, situaciones en las cuales no habría habido culpa del deudor, explicándola los autores clásicos, ya en razón de un expreso convenio, ya de una garantía tácita asumida por el deudor.
- * Los casos donde funciona tácitamente la *custodia*, aparte del comodatario, y del sastre o del tintorero, abarcan también al dueño de un navío, de un hospedaje o de un establo, que deben responder por lo que le sucediere a las cosas incorporadas a esos ámbitos por los clientes. También al arrendador de una cosa mueble y al acreedor pignoraticio respecto de la cosa dada en prenda, aunque éste se excusase por mero caso fortuito.
- * En la época posclásica, esta idea de la *custodia* irá siendo reemplazada por la noción análoga de la *exactissima diligentia* (empleo de una diligencia máxima, superior a la normal), por la cual responden las personas señaladas en la época clásica para la *custodia*.

EL DOLO

Se entiende que hay dolo como causal de incumplimiento de una obligación cuando el deudor ha cometido un hecho o una omisión deliberada efectuada para perjudicar al acreedor.

- * Debe ser ejecutado por una persona con discernimiento. Así, no puede ser atribuido a un *furius**, a un *infans** o a un *impuber infantiae proximus*.*
- * El dolo no se presume, sino que es el acreedor quien debe probarlo.
- * El *pactum de dolo non praestando* —en virtud del cual se establece con anticipación que el deudor no será responsable por el dolo— afecta al orden público y por ello es nulo; sin embargo, el acreedor puede renunciar voluntariamente a demandar los perjuicios debidos al dolo.

82

5.04 1

81

LA CULPA

Se entiende que hay culpa como causal de incumplimiento de una obligación cuando éste se debe a una imprudencia o a una negligencia imputable al deudor.

I. Hay varias clases de culpa. Un ejemplo es la culpa grave (*culpa lata*), entendiéndose por tal una suma negligencia. Ulpiano dice "no entender lo que todos entienden". Es el caso de quien, teniendo objetos preciosos, deja abierta la puerta de su casa.

La *culpa lata* es asimilada en sus efectos al dolo.

II. Está también la culpa leve (*culpa levis*), consistente en la mera negligencia o imprudencia en el trato o cuidado de las cosas.

- A veces, esta *culpa levis* era juzgada *in abstracto*, a cuyos efectos se la compara con la conducta paradigmática de lo que hubiera hecho en iguales circunstancias un *diligens paterfamilias*.
- Responden por una culpa de este tipo el vendedor, el mandatario y el acreedor prendario.
- Otras veces, la *culpa levis* era juzgada *in concreto*, es decir cotejándola con la habitual conducta propia del deudor: hay culpa cuando éste comete un descuido que no habría cometido con sus propios asuntos.
- Responden por esta culpa el marido deudor de la dote a su mujer; el tutor y el curador respecto del pupilo; el copropietario respecto a los otros condóminos.

RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO CULPABLE

I. Durante la vigencia del procedimiento formulario, si el deudor, en forma dolosa o culpable, no daba cumplimiento a la obligación, la regla general era que el juez sólo podía constreñirlo al pago de una suma de dinero por daños y perjuicios.

- Al no obtener realmente el objeto debido, el acreedor muchas veces no alcanzaba completa satisfacción por el pago de esas sumas de dinero.
- Encontramos aquí una consecuencia de la idea de la *litis contestatio*.

como novación; al transformarse la obligación antigua en la que figuraba en la fórmula, había que aplicar esta última, por lo que se abría la puerta para la condenación pecuniaria.

II. Cuando aparece el procedimiento extraordinario —ya se ha visto—, la regla general será reformada, y, siendo ahora el juez un funcionario que cuenta con la fuerza pública, condena al deudor demandado a la ejecución de la prestación toda vez que ésta sea posible.

- Si la prestación es de entrega de una cosa, el *iudicatus* (condenado) será obligado a ponerla a disposición del actor. Si la prestación es imposible o consiste en un *facere* —no se puede coaccionar el cumplimiento—, entonces sí se resolverá en daños y perjuicios.
- Esta idea es más cercana a nuestras concepciones procesales.

El contenido de los daños y perjuicios. — Podía variar de acuerdo con la modalidad de la fórmula.

(A) Si era de derecho estricto y contenía una *condemnatio certa*, el juez se limitaba a condenar por el monto de la suma allí indicada.

(B) Si era de derecho estricto, pero con *condemnatio incerta*, entonces la suma era fijada por el juez, a veces hasta el monto tope de una *taxatio*; y de no existir ese tope, por cuanto él estimare el valor de la cosa. El actor podía también, bajo juramento (*iusiurandum in litem*), fijar el monto de lo que estimare que correspondiera condenar. En este caso el juez no está obligado por dicho juramento, que jugaba como un elemento de juicio.

(C) En las *actiones bonae fidei* el juez se encuentra más libre respecto de la suma a condenar, ya que las juzga conforme a la equidad (*ex aequo et bono*).

Conforme a ello la condena no solamente puede abarcar el daño directo producido por la inejecución (*damnum emergens*), sino también la utilidad que se esperaba obtener y que por el incumplimiento no se obtuvo (*lucrum cessans*).

- Justiniano determinó que los daños y perjuicios no podrían superar el doble del monto del valor determinado de la prestación.
- Podía ocurrir, a veces, que las partes hubiesen convenido con anticipa-

39

ción —para evitar la incertidumbre de la fijación por el juez— el monto de los perjuicios a pagar en caso de incumplimiento. A esto se lo denominaba *stipulatio poenae* (cláusula penal).

- La forma para establecerla era una *stipulatio*. En la primera época se la hacía formulando una sola pregunta: "Si no me das al esclavo Stichio, ¿prometes darme 100?". Luego se la perfeccionó determinándola del siguiente modo: "¿Prometes darme al esclavo Stichio?; si no me dieras a Stichio, ¿prometes darme 100?".

EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO

El mero retardo culpable —ya del deudor en el cumplimiento de la obligación; ya del acreedor en recibir el pago— podía, en ciertos casos, tener importantes consecuencias. Ese retardo se denomina genéricamente *mora*.

Mora del deudor. — Para que exista mora del deudor deben darse las siguientes condiciones.

(A) Un retardo del cumplimiento de la obligación, para lo cual ésta debe ser válida y exigible, que no lo es si media un plazo o se le puede oponer una *exceptio*.

(B) Ese retardo debe ser doloso o culpable por parte del deudor.

(C) En ciertos casos es necesaria una conminación expresa por parte del acreedor al deudor (*interpellatio*).

- Cuando es necesaria la *interpellatio* se suele hablar de *mora ex persona*.
- En cambio no es necesaria cuando la obligación es a término, pues en este caso se interpreta que *dies interpellat pro homine* (el plazo interpela en lugar del hombre). Se dice, entonces, que la mora es *mora ex re*.
- Otro caso de *mora ex re* acaece a propósito de las obligaciones delictuales, en las cuales no es necesaria la *interpellatio*, pues los obligados quedan por el solo hecho del cometido del delito en mora.

La mora agrava la situación del deudor.

(A) Tiene la obligación de responder por los riesgos de la cosa, incluso si ésta perece por caso fortuito, ya que se entiende que a su respecto se ha perpetuado la causa de la obligación (*perpetuatio obligationis*).

- Por una razón de equidad se admitió posteriormente que quedaba liberado el deudor si probaba que la cosa lo mismo hubiera perecido de estar en manos del acreedor.

(B) Si se trata de una obligación de buena fe, entonces, a partir de la mora, son debidos los intereses —en caso de tratarse de una suma de dinero— o los frutos —en caso de tratarse de una cosa fructífera.

- Estos intereses son llamados *moratorios* para diferenciarlos de los meramente convencionales, a los cuales se agregan.
- Si la obligación es de derecho estricto, los frutos son debidos no a partir de la mora, sino de la *litis contestatio*; los intereses *moratorios*, en cambio, ni siquiera son debidos a partir de la *litis contestatio*.

(C) La mora del deudor cesa cuando cumple la prestación debida, aun cuando el acreedor no la acepte. En este supuesto incurriría, en principio, en mora el acreedor.

Mora del acreedor. — El acreedor se encuentra en mora cuando no acepta la prestación que le ofrece cumplir el deudor en tiempo y forma. Consiste ésta, pues, en un retardo en la recepción.

- Para que se dé este supuesto es necesario que el ofrecimiento del deudor sea correcto: si debía llevar la prestación al acreedor, que así lo hubiera hecho; si en cambio fuese el acreedor quien debía retirar la cosa, bastaría la simple oferta por parte del deudor. Incluso se podía obviar esto último de existir un plazo, pues era al acreedor al que le incumbía el retiro. Igualmente, la recepción de la prestación puede quedar frustrada por un acto del acreedor.

La mora del acreedor tenía los siguientes efectos:

(A) El deudor se liberaba de los riesgos de la cosa, respondiendo solamente en caso de que hubiera cometido dolo.

(B) El deudor podía hacerse reembolsar los gastos devenidos por la conservación de la cosa.

(C) El deudor podía consignar* el dinero y las cosas debidas, sellándolos y depositándolos en un lugar público, como ser un templo.

- Un caso muy particular y curioso tenía lugar, por ejemplo, con la demora de un comprador en aceptar el vino comprado: si el vendedor necesitaba los barriles, podía derramar su contenido. Justiniano exigirá que éste último notifique previamente al acreedor remiso.

(D) Con la mora del acreedor cesan los intereses que se debieran por mora del deudor —es decir, los *moratorios*—; luego de la consignación, cesan también los intereses convencionales.

FRAUDE DEL DEUDOR EN PERJUICIO DE LOS ACREEDORES

I. El deudor, no obstante la obligación contraída, no pierde la libre disponibilidad negocial. Puede celebrar otras y vender bienes; pero si estos negocios de transmisión de cosas —que en principio tienden a disminuir su patrimonio— llegasen a ubicarlo en una situación de insolvencia, entonces el acreedor vería peligrar el pago de la obligación. En tal caso se entiende que ha habido fraude (*fraus*) cometido en perjuicio de los acreedores cuando el deudor deliberadamente provocó con sus enajenaciones una situación de insolvencia, que se agravaría de ser ya insolvente el deudor.

II. Desde fines de la República, el pretor fue concediendo remedios a favor de los acreedores que sufrían los perjuicios del fraude de su deudor.

(A) Los acreedores tenían, durante la ejecución de los bienes del deudor (*bonorum venditio*), la posibilidad de designar un *curator bonorum*. Este se encargaba de cuidar los bienes del *fraudator* y podía lograr una *restitutiones in integrum* por parte del pretor, quien tenía por no celebrados ciertos actos jurídicos concluidos con terceros que, comportándose como cómplices del deudor, habían evadido bienes del patrimonio del que los acreedores esperaban cobrarse.

* Además, al *bonorum emptor* (comprador del patrimonio del deudor) se le concedían acciones *in factum* para lograr la rescisión de ciertas ventas; del mismo modo, podía oponer frente a ciertos créditos fraudulentos la *exceptio fraudis*.

(B) Igualmente los acreedores tuvieron un *interdictum fraudatorium* por medio del cual se procuraba la restitución de aquellas cosas del deudor que estuvieran fraudulentamente en

poder de terceros, a quienes se los conminaba a revocar el acto, pues de lo contrario —por una *formula arbitraria*— eran condenados por un valor igual al saldo del patrimonio del deudor.

* La *restitutio in integrum* aparecía más ligada a los casos de *bonorum venditio*; en cambio, el *interdictum fraudatorium* era más amplio y funcionaba como el remedio normal contra el fraude del deudor.

ACCION PAULIANA

En el derecho posclásico estos dos remedios parecen haberse refundido en una *actio in factum amplia* —vulgarmente llamada Pauliana—, la cual tiene por objeto revocar todos los actos realizados fraudulentamente por el deudor en perjuicio de sus acreedores.

I. Para que funcionase era necesario:

(A) Que se hubiera celebrado un acto jurídico de resultados del cual quedaba empobrecido el deudor. No importaba la naturaleza de dicho acto; podía ser una venta, una donación, una obligación, la remisión de una deuda, etcétera.

(B) Que el acto hubiera causado un perjuicio a los acreedores. Bastaba con probar que el deudor no podía pagar sus deudas porque, por ejemplo, su pasivo era superior a su activo.

(C) Que el deudor tuviera conciencia del fraude (*consilium fraudis*), lo cual era interpretado de manera amplia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

II. La acción Pauliana, si bien podía ser ejercida contra el deudor, resultaba más eficaz contra los terceros que hubieran realizado negocios con aquél. Podían darse distintas situaciones:

(A) Que los actos fueran a título gratuito —reuniéndose los requisitos señalados para ello—, y en tal caso la revocación de los mismos progresaba sin dificultades.

(B) Que se tratara de actos a título oneroso, en cuyo caso había que probar que el tercero era cómplice del deudor en el

fraude; es decir, que conociendo el estado de insolvencia de éste, lo mismo hubiera realizado el negocio.

En cambio, si el tercero había realizado el acto a título oneroso y de buena fe, es decir, ignorando la situación del deudor, la revocación no lo alcanzaba.

III. La acción Pauliana —o revocatoria— era una *actio arbitraria* por la cual el juez no condenaba a menos que el tercero se negase a restablecer el estado de cosas existente antes de la celebración del acto objeto de revocación.

- * Así, si se le transmitió el dominio de una cosa, debe retransferirlo; si hubo remisión* de una deuda, la obligación se restablece.
- * Intentada dentro del año útil después de la *bonorum venditio* —en caso de rehusarse el restablecimiento del estado de cosas—, la condena era por la totalidad del perjuicio sufrido. Intentada después de pasado el año, era sólo por el monto de lo que se hubiesen enriquecido el deudor, los terceros y los herederos.

EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

I. En el viejo procedimiento de las *legis actiones**, la ejecución se realizaba por la *manus iniectio** y por la *pignoris capio**.

En el procedimiento formulario subsiste la ejecución personal, pero fundamentalmente prevalecerá la ejecución sobre los bienes bajo la forma de un concurso general del patrimonio del deudor.

II. Una vez que el deudor ha sido condenado (*iudicatus*) o confesó estar obligado (*confessus*), podía intentarse la *actio iudicati*.*

- * De acuerdo con la ley de las XII tablas, para poder iniciar la ejecución era necesario dejar transcurrir un plazo de 30 días.
- * Vencido este plazo quedaba expedita la vía de ejecución. El deudor podía oponerse a la *actio iudicati**, pero corría el riesgo de la *litis crescentia*, que implicaba una eventual condena por el doble de lo debido.

Transcurrida esta instancia podrá pedirse ya la ejecución personal, ya la ejecución sobre los bienes, o ambas a la vez.

1). La ejecución directa y personal —en virtud de la *actio iudicati*— autorizaba al acreedor a retener al deudor condenado o confeso como prisionero suyo.

- * No obstante la dureza de esta prisión por deudas, continuará en todas las épocas posteriores. Acá aparece un tanto despojada de ciertos caracteres de la *manus iniectio*, limitándose a la retención personal.
- * Una *lex Iulia* —de la época de Augusto— le permitirá al deudor evitar esta ejecución por medio de la *cessio bonorum* (cesión de su patrimonio [a los acreedores]).
- * Por otra parte, podían evitar la encarcelación los deudores que gozaran del beneficio de competencia*.

2). Pero a partir del siglo II a.C. —más precisamente hacia el 118 a.C.— surge un nuevo procedimiento, atribuido al pretor Rutilio Rufo, por medio del cual se procederán a ejecutar los bienes del deudor. Este procedimiento es conocido como *bonorum venditio*.

BONORUM VENDITIO

Puede ser iniciada por un solo acreedor contra el deudor condenado, o confeso, o que haya huido abandonando sus bienes. El procedimiento se desarrollaba contra el patrimonio de la persona viva o del dejado por un muerto.

(A) El acreedor solicita primeramente del pretor una *missio in possessionem* —que lo ponga en posesión de los bienes del deudor— a los efectos de asegurar preventivamente la no dilapidación o desaparición de los mismos.

- * Si se trataba de varios acreedores que podían la posesión de los bienes, el pretor designaba entre ellos un *curator bonorum* (cuidador de los bienes).

(B) Al mismo tiempo se hacían colocar afiches (*proscriptiones*) en los lugares públicos a fin de hacer enterar, a cualesquiera otras personas interesadas, del comienzo del procedimiento, ya fueran otros acreedores, ya fueran amigos del deudor que quisieran pagar por él.

(C) Al cabo de 30 días de ocurrida esas publicaciones

—que se reducían a 15 si el deudor había muerto—, el pretor daba un segundo decreto ordenando a los acreedores a que se reuniesen con el fin de elegir entre ellos un *magister bonorum*, quien se encargaría de realizar la venta.

- * Este *magister bonorum* debía ordenar los bienes preparando la subasta por medio de una *lex venditionis*, donde figura el inventario del activo y del pasivo.

(D) Luego de un nuevo plazo —10 días si el deudor estaba vivo, 5 si estaba muerto—, el *magister* procedía a vender el patrimonio en pública subasta.

Resultaba comprador (*bonorum emptor*) aquel que ofreciera pagar el mayor porcentaje de las deudas del ejecutado.

- * El interés de la subasta residía en calcular, de acuerdo con la diferencia entre los bienes que aún quedaban y las deudas denunciadas, hasta qué porcentaje (*portio*) resultaba beneficioso pagar.

De acuerdo con este procedimiento, lo que se ha realizado es una sucesión * universal inter vivos, de la cual el causante es el deudor ejecutado y el sucesor es el *bonorum emptor*.

(A) Respecto de los bienes, este *bonorum emptor* adquiere la propiedad bonitaria de los mismos, accediendo al *dominium* * *ex iure quiritium* luego de pasados los plazos de *usucapio* *.

- * Para poder entrar en posesión de los mismos tenía un *interdictum possessorium*.

(B) Respecto de los créditos que hubiera en el patrimonio adquirido, no los hace suyo *ipso iure*; pero el pretor le concederá, de estar vivo el deudor, la *formula Rutiliana*, y de estar muerto, la *actio Serviana*.

- * La *formula Rutiliana* pertenecía a la clase de fórmulas con transposición de sujeto. En la *intentio* se hace figurar el nombre del deudor

ejecutado, pero en la *condemnatio* el del *bonorum emptor*, de tal modo que éste obtenía el beneficio de la sentencia y podía cobrar el crédito.

- * La *actio Serviana* —que no hay que confundir con la que dio origen a la hipoteca*— era una *actio ficticia*. El pretor hacía de cuenta que el *bonorum emptor* era lo mismo que un heredero del deudor ejecutado.

(C) Respecto de las deudas, el *bonorum emptor* estaría obligado a pagarlas hasta el porcentaje que ofreció en la subasta. El pretor otorgará acciones a los acreedores transponiendo los nombres y haciendo figurar al deudor ejecutado en la *intentio* y al *bonorum emptor* en la *condemnatio*, quedando éste obligado a responder.

Para el deudor ejecutado, la *bonorum venditio* trae la tacha de infamia *, quedando igualmente expuesto a acciones de sus acreedores por lo no cobrado.

DISTRACTIO BONORUM

En casos muy excepcionales se permitirá la *distractio bonorum*, cuya diferencia con la *bonorum venditio* consistía en que los bienes eran rematados en forma individual hasta equiparar el monto de las deudas.

- * Tenía este beneficio el incapaz de hecho que carecía de tutor o de curador; igualmente, los senadores y, en general, los acreedores podían proponer al deudor que aceptara esta forma de liquidación de las deudas.
- * Este procedimiento irá reemplazando en la época posclásica a la *bonorum venditio*.

BONORUM SECTIO

Era la venta pública realizada por el estado de bienes conseguidos en una guerra o como confiscación en procesos criminales.

- * Podía ser efectuada en forma individual; o en forma universal, si se trataba del patrimonio de una persona.
- * El comprador (*bonorum sector*) adquiría la propiedad inmediatamente después del pago, otorgándosele en favor, o en contra, en caso de

de haber adquirido un patrimonio, acciones análogas a las concedidas al *bonorum emptor*.

BONORUM CESSIO

El deudor insolvente que de buena fe resultase cargado de deudas podía evitar el proceso infamante de la *bonorum venditio* haciendo cesión de todos sus bienes a sus acreedores (*cessio bonorum*).

• Se le otorgaba también el beneficio de competencia por tiempo ilimitado para favorecer su recuperación económica.

EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

La forma normal mediante la cual se logra la extinción de una obligación es el cumplimiento de la prestación debida, es decir, el pago; pero el derecho —en virtud de las múltiples hipótesis que pueden darse en los negocios— reconoce además la existencia de otros modos de extinción. Generalmente se los suele agrupar de la siguiente manera.

(A) Unas veces la obligación se extingue *ipso iure* (de pleno derecho), lo cual significa que mediando el supuesto determinado, el deudor queda automáticamente liberado.

(B) Otras veces, la causal determinada no obsta a la subsistencia de la obligación, pero el pretor —por razones de equidad— priva a la misma de eficacia concediendo al deudor que así lo pida una *exceptio* * para detener el progreso de la *actio* *. Estos modos se denominan *per exceptionem* (por una excepción) o también *ope exceptionis* (por obra de una excepción).

MODOS PRIMITIVOS DE EXTINCIÓN

En la época primitiva existieron dos modos de extinción muy formales, que eran la *solutio per aes et libram* y la *acceptilatio*.

SOLUTIO PER AES ET LIBRAM

Era un pago solemne realizado en presencia de por lo menos cinco testigos y un *libripens* (que sostiene la balanza). Aquel al que le correspondía pagar debía decir, sosteniendo en la mano una moneda de cobre, la siguiente fórmula: "Puesto que debo pagar, me libero correctamente por medio de este cobre y de esta balanza de bronce. Pesa tú en esta balanza por primera y última vez de acuerdo con la ley pública". Golpeaba luego con el cobre la balanza y se lo daba al acreedor a título de pago.

- La palabra *solutio*, imperfectamente traducida por pago, significa más bien "liberación", y tenía relación con el vínculo nacido del *nexum**, cuya denominación proviene de *nectere* (ligar, atar).
- El rito de la balanza se debía a que en los tiempos primitivos —en los que no existía dinero amonedado— se solía pagar con trozos de cobre bruto que debían ser pesados.
- Pero posteriormente se recurrió al uso de utilizar una sola moneda (*nummo uno*), acto que se lo llamaba "pago imaginario" (*solutio imaginaria*).
- Esta acción sirve para liberarse de la "responsabilidad" de la obligación —en el sentido del *Haftung* de los alemanes—; aquí se ve con claridad como el mero pago de la prestación, es decir del *debitum* (*Schuld*, para los alemanes), no extingue la obligación, necesiándose este rito formal para realmente desvincularse. Y esto era así hasta tal punto, que si se realizaba la *solutio per aes et libram* —permitida por el acreedor— sin haberse efectuado la prestación, la obligación se extinguía *ipso iure*.
- En un principio se la utilizaba para extinguir la obligación nacida del *nexum*; pero también en el caso de la obligación del condenado en juicio (*condemnatus*) y del que había sido condenado a cumplir un legado *per damnationem**. Según Gayo, se seguirán usando estas dos últimas formas como medio de extinción, pero en la época de Justiniano dejarán de utilizarse, al igual que los otros negocios *per aes et libram*.

ACCEPTILATIO

Es una forma solemne de asegurar el pago de una obligación nacida de un contrato verbal consistente en una pregunta y su respectiva respuesta. El deudor preguntaba al acreedor: "¿Tienes por recibido lo que te he prometido (dar o hacer)?", a lo cual éste respondía: "Lo tengo".

85

504 1

84

- Se nota fácilmente el parecido que tiene esta forma con los contratos verbales, como la *sponsio* o la *stipulatio*, con la diferencia de que en estos ritos la pregunta y la respuesta están enfocadas a obligarse; en la *acceptilatio*, en cambio, a desobligarse.
- Esto es una aplicación —caso igual ocurre en la *solutio per aes et libram* respecto del *nexum*— de un principio genérico utilizado por los romanos, según el cual todo aquello que se contrae por un rito determinado, se extingue por un rito contrario.
- Desde un principio la *acceptilatio* debía suceder con posterioridad a un pago efectivo, por lo que venía a servir de medio probatorio, lo cual se acomoda a la realidad de las palabras empleadas. Posteriormente vino a cumplir un papel más abstracto (*imaginaria solutio*), pudiéndose emplear para remitir o perdonar una deuda, teniendo ello una ventaja sobre el *pactum de non petendo*, ya que con la *acceptilatio* se extingue la obligación *ipso iure* y no *ope exceptionis*.
- Por este medio se extinguen las obligaciones nacidas de un contrato verbal —al parecer, también las de un contrato literal, aunque ignoramos cuáles eran las formas al respecto—, pero no las de otros contratos o fuentes, salvo que estas últimas se transformasen en *stipulationes* por medio de una novación (*Aquilian stipulatio*).

MODOS DE EXTINCIÓN "IPSO IURE"

PAGO

El pago —en general *solutio*— consiste en el cumplimiento de la prestación debida, sea ya de un *dare*, de un *praestare* o de un *facere*.

- La expresión *solutio* va a alcanzar un sentido distinto del primitivo —liberación, desligamiento— para referirse al objeto de la prestación: *pecuniam solvere* (pagar el dinero).
- Al ser un modo no formal, la prueba se independizaba, lo que no ocurría con la *solutio per aes et libram* o con la *acceptilatio*. Generalmente se utilizaban testigos; o, mejor aún, recibos, como será la costumbre en la época imperial.

(A) Quién debe pagar. — En principio el que paga es el propio deudor, pero también resulta válido y extingue la obligación el pago efectuado por un tercero, siempre que no se refiera a una prestación que necesariamente debiera ser cumpli-

da por el deudor mismo, como sería el hacer una estatua, pintar un cuadro, etcétera.

En el caso del pago por un tercero, éste puede hacerlo con consentimiento del deudor, sin saberlo el deudor y aun en contra de la voluntad del deudor.

- En el primer supuesto —con consentimiento del deudor— se configura el mandato. Aquel que ha pagado, si el deudor mandante no le devuelve lo pagado, puede exigírselo por medio de la *actio mandati contraria* hasta el monto de lo ordenado pagar.
- En el segundo supuesto —sin saberlo el deudor— se configura, en caso de prestarle un servicio útil y sin *animus donandi*, la figura cuasicontractual de la "gestión de negocios". El tercero tendrá la *actio negotiorum gestorum contraria* para recobrar lo pagado hasta el monto de la utilidad prestada. Así, si pagó más de lo debido, sólo podrá demandar hasta el límite real de la deuda, sin perjuicio de poder repetir lo pagado indebidamente del propio acreedor por la *condictio indebiti*.
- En el tercer supuesto —en contra de la voluntad del deudor—, en derecho estricto no tiene acción para recobrar lo pagado, pese a que el pago resulta válido. Sin embargo, el que paga puede obtener la cesión de acciones por parte del acreedor, e incluso hay también algunos remedios para evitar el injusto enriquecimiento en provecho del deudor: así, la *actio negotiorum gestorum contraria* ejercida como *actio utilis*, y en los tiempos del Bajo Imperio, también la *actio de in rem verso*, extendida por analogía y como *actio utilis*.

(B) A quién se debe pagar. — En principio se debe pagar al acreedor, pero se pueden dar otros supuestos.

- Así, se puede pagar a un *procurator* o a un mandatario del acreedor.
- Igualmente se puede pagar a un acreedor adjunto, tal como sucede con el caso del *adstipulator*.
- Un caso especial es el del *solutionis causa adiectus* (agregado por causa del pago), es decir, la persona que se designa en la *stipulatio* para que pueda receptor el pago. Esta figura no debe ser confundida con la anterior del *adstipulator*, ya que no es un coacreedor como éste, sino que figura allí al solo efecto de recibir el pago, sin poder intentar el cumplimiento de la obligación por una acción, ni cederlo, ni remitirlo; más aún, si muere esta persona, el deudor no se puede liberar del pago pagando a sus herederos. Sin embargo, es más que un simple mandatario, ya que por ser parte de la *stipulatio* no puede ser revocado, pudiendo el deudor optar entre pagarle a él o al acreedor, aun cuando éste manifieste lo contrario.
- En el supuesto de que el acreedor fuese un pupilo, no podía aceptar un pago sin la *auctoritas* de su tutor. Si no obstante lo hacía sin

cumplir este requisito, quedaba establecido que se convertía en propietario de la suma recibida; tanto era así, que en la época clásica se estableció que no podía reclamar por segunda vez el pago, y si lo hacía, se otorgaba al deudor la *exceptio doli*°.

- ° El pago quedaba liberado si se lo efectuaba a una persona distinta al acreedor, siempre que éste ratificara dicho acto (*ratihabitio*).

(C) Qué es lo que se debe pagar. — El deudor debe cumplir la obligación pagando exactamente el objeto establecido en la prestación. De esto se derivan las siguientes consecuencias.

1) Que el acreedor no está obligado a aceptar el pago de un objeto distinto. Sin embargo, no está prohibido que lo acepte, produciéndose en este caso el supuesto de la *datio in solutio* (dación en pago), que traía como consecuencia la liberación de la obligación por parte del deudor.

- ° Los sabinianos entendían que si el acreedor aceptaba que le pagaran con una cosa distinta, la obligación se extinguía *ipso iure*; los proculeyanos, en cambio, sostenían que sólo le otorgaba al deudor la posibilidad de defenderse mediante una *exceptio doli*, y por lo tanto, sería una extinción *ope exceptionis*. Justiniano se inclinó por la solución sabiniana.
- ° En la última época —por influencias del derecho greco-egipcio—, en textos interpolados del "Digesto" y del "Código", se interpretará a la *datio in solutio* como si fuera una venta realizada por el deudor al acreedor respecto de la cosa dada en pago, por el precio de la prestación debida. Por ello es que al acreedor se le otorgará una *actio empti*° *utilis* por los vicios de evicción°.

2) Que el acreedor no puede ser obligado a recibir prestaciones parciales en contra de su voluntad. Una excepción a este principio sería el *beneficium competentiae* (beneficio de proporción), en virtud del cual el acreedor no podía ejecutar al deudor por el todo, sino dentro de los límites de las posibilidades de pago de éste.

- ° Así, gozaban de este beneficio —nombre no estrictamente romano, sino dado por los intérpretes— muy pocas personas: (A) el marido ejecutado por su mujer al pago de la dote; (B) los ascendientes demandados por sus descendientes; (C) los patronos demandados por sus libertos; (D) el donante respecto a quien el donatario llevara a cabo una acción personal derivada de la donación; (E) el deudor que hubiese efectuado la *cessio bonorum*° (cesión voluntaria de sus bienes) a sus acreedores en virtud de la *lex Julia*; (F) el socio respecto al socio.

- ° Los beneficiados no eran considerados insolventes, evitando la *bonorum venditio*°, con sus consecuencias de la prisión y la nota de infamia.
- ° Este principio de no poder obligar al acreedor a recibir el pago de prestaciones parciales aparece atenuado en un fragmento de Juliano donde opina que "parece el pretor obrar con más humanidad si compele al actor a recibir lo que se le ofrezca, puesto que a su ministerio corresponde disminuir los pleitos".
- ° Se podía también dar el supuesto de que un acreedor tuviera varios créditos contra un mismo deudor. Si éste pagaba con una suma que no satisficiera a todos ellos, la imputación del pago podía ser efectuada, en primer lugar, por el deudor, y si éste no lo hacía, por el acreedor. En caso de que nadie dijese nada, se seguían reglas especiales en favor del deudor. Así, se imputaba la suma a los intereses antes que al capital; también, al crédito ya vencido antes del que faltaba vencer; si todos estaban vencidos, primero a los más gravosos, y si todos eran igualmente gravosos, el pago se distribuía proporcionalmente entre ellos.

(D) Cuándo se debe pagar. — El principio general es que hay que respetar lo establecido en el negocio —así, cuando hay un plazo—. Si nada se hubiere dicho, entonces el acreedor —atendidas las circunstancias y características de la prestación— podrá exigir el pago en forma inmediata.

- ° Fue común en la época posclásica, debido a las crisis económicas, el otorgamiento de moratorias por disposición imperial.

(E) Dónde se debe pagar. — En principio, el lugar de pago es el fijado en el negocio respectivo. Si nada se hubiera establecido, se estimaba que las prestaciones individualizadas en forma determinada debían ser satisfechas en el lugar en que éstas se hallaren. Si las prestaciones eran genéricas, debían ser cumplidas en el lugar en que pudieran ser exigidas, ordinariamente en el domicilio del deudor.

- ° Para el supuesto de que el acreedor exigiera el cumplimiento en un lugar distinto del convenido, el pretor concedió la *condictio de eo quod certo loco*. Por medio de ella, el deudor se beneficiaba en la misma medida de los perjuicios que le hubiera ocasionado el tener que pagar en otro lugar. Esta ventaja puede resultar apreciable cuando se trata de cosas genéricas, como el vino, el aceite, el trigo, etcétera, cuyos precios varían según las localidades; lo mismo ocurre con el dinero, que no produce en todas partes el mismo interés.
- ° El cálculo del valor se hizo, en principio, en el sólo beneficio del deudor; más tarde también se contemplará el interés del acreedor.

86504-1

85

(F) Pago por consignación. — Si el acreedor se negaba a aceptar el pago, por lo cual incurría en mora, el deudor podía pagar depositando en forma pública el objeto debido. Esto será considerado un pago liberatorio que extingue la deuda con todos sus accesorios.

- La denominación posterior de "pago por consignación" se debió a los sellos que se les ponían a los objetos entregados por el deudor para asegurar la inviolabilidad de los mismos.
- Si se trataba de una cosa mueble, ésta era llevada a un establecimiento público y, más generalmente, a un templo. Allí se la sellaba (*obsignatio*) y se la depositaba (*depositio*).
- Si se trataba de un inmueble, lo común era ponerlo en estado de "sequestro" (*sequestratio*), quedando en posesión de un tercero denominado "sequestrario".

NOVACION

La novación (*novatio*) consiste en la transformación de una obligación en otra nueva, de tal modo que la primera queda extinguida y se la sustituye por esta otra.

- Son típicamente novatorios los *nomina transcripticia**, a través de los cuales se ve la utilidad de empleo de este modo, ya para cambiar la naturaleza del vínculo obligacional —caso a *re in personam*—, ya para cambiar la persona del deudor o del acreedor —caso a *persona in personam*—.
- Pero el modo normal de establecer una *novatio* voluntariamente es por el empleo de una *stipulatio*. Así, por ejemplo: "Los cien que tu me debes por la compraventa, ¿prometes dármeles por la *sponsio*?" Acá se extingue la obligación de la compraventa y nace una nueva, donde los cien son debidos ahora por una *sponsio*.
- Igualmente, podía ser novatoria la *dotis dictio** en el caso de que quien se comprometiera a constituir la dote fuera un deudor de la mujer —se extingüía la obligación respecto de ésta y quedaba como nueva la de dote.

Condiciones para que exista la novación. — Para que se pueda operar la novación son necesarios los siguientes requisitos:

(A) [Una obligación anterior.] Resulta elemental, puesto que

no se puede extinguir lo que no existe. [Esta obligación puede ser ya de origen contractual, ya delictual; también una obligación natural o civil.]

(B) La concertación de una nueva obligación. Hemos visto que la forma normal era mediante el empleo de la solemnidad de la *stipulatio*, sin perjuicio de los casos menores de los *nomina transcripticia* y de la *dotis dictio*.

(C) El *animus novandi*. Este requisito será exigido por Justiniano. Anteriormente, en la época clásica, los autores no habían hablado de él, refiriéndose únicamente a las formas contractuales empleadas para deducir de allí la existencia de la novación. Por la decadencia del formalismo* en el Bajo Imperio se recurrió —como en otras cuestiones— a interpretar la voluntad de las partes. De ahí que para Justiniano sólo tendrá validez cuando se declare expresamente la voluntad novatoria (*animus novandi*).

- Esta cuestión es un poco compleja debido a que la constitución de Justiniano no resulta del todo clara. Su propósito principal fue terminar con una serie de presunciones de novación que se habían venido estableciendo. Habla, en cambio, de una *voluntas non lege* (voluntad no presumida por la ley), exigiéndose no solamente que la voluntad fuese determinada, sino que, además, fuese manifestada en términos expresos.
- De no ser así habría dos obligaciones: la anterior no extinguida y la nueva.

(D) El mantenimiento en la nueva obligación del mismo objeto que en la primera. La exigencia del *idem debitum* (misma prestación) fue propia tanto de la época primitiva como de la época clásica. Así, si alguien se comprometía a entregar un usufructo para reemplazar una deuda proveniente de un mutuo, los autores clásicos manifestaban que no había extinción de la primera obligación y que ésta subsistía juntamente con la nueva.

- Esta idea queda muy bien expresada en la definición de Ulpiano, quien, cuando habla de la *novatio*, emplea las palabras "transfusión y translación" (*transfusio atque translatio*) de una obligación a otra, que recalcan el sentido de que si bien algo nuevo se añade, algo de lo viejo debe continuar.

- * Este principio se debilitó en algo por cuanto el pretor reconoció al deudor perseguido en juicio por la primera obligación una *exceptio pacti conventi* (excepción de pacto convenido).
- * Justiniano parece que, por lo menos implícitamente, aceptó el cambio de objeto en la novación, lo cual resulta usual en el derecho moderno.

(E) Que se agregue algo nuevo (*aliquid novi*). Este requisito resulta elemental por cuanto, de lo contrario, no habría ocasión de dar lugar a una novación.

Debemos acá distinguir dos clases de supuestos:

1) Cuando se produzca sin cambiar las partes (*novatio inter eadem personas*). En este caso, el "algo nuevo" debe consistir —ante la imposibilidad de cambiar el objeto— ya en un cambio de la naturaleza de la obligación ("Los 100 que me debes por la compraventa [contrato consensual], me los deberás por la *stipulatio*" [contrato verbal]), ya en una adición o supresión de alguna modalidad, como sería el agregar o suprimir una condición o un plazo.

2) Cuando se produzca cambiando alguna de las partes (*novatio inter novas personas*). En este caso puede variarse la persona del acreedor o la persona del deudor.

- * Cuando se cambia el acreedor las cosas ocurren así: A es acreedor de B. El objeto es que B, en lugar de abonar a A lo haga a C. Para ello se deberá contar con el acuerdo del primer acreedor, del propio deudor —que se podría rehusar— y del segundo acreedor. Logrado el acuerdo, el nuevo acreedor, C, le pregunta por la *stipulatio* a B: "Los 100 que tú le debes a A, ¿prometes pagármelos a mí?". Esto tenía interés práctico cuando se querían evitar sucesivos pagos: por ejemplo, si el primer acreedor le debía 100 al segundo acreedor.
- * Cuando se cambia el deudor las cosas ocurren así: el acreedor A, que tiene una obligación respecto del deudor B, verá cambiado a este último por un nuevo deudor C. Por ejemplo, A le preguntará al nuevo deudor C en la *stipulatio*: "¿Prometes darme los 100 que me debe B?". De este modo se extingue la primera obligación y queda formalizada la segunda entre A y C.
- * La llamada *delegatio* es un caso muy particular —que a veces encierra una novación y otras no— en el cual intervienen tres personas: el delegante, el delegado y el delegatario. Así, el delegante, por medio de una orden (*iussu*), le indica a su deudor —delegado— que deberá contraer esa misma obligación con otra persona —delegatario—. Esta *delegatio* sería activa, por cuanto hay un cambio de acreedor.
- * También podía ser pasiva si lo que se cambiaba era el deudor. Por ejemplo, si el delegatario tiene un crédito respecto del delegante, éste

puede obtener que otra persona —delegado— lo reemplace. Entonces, el delegatario le preguntará a este tercero: "Los 100 que me debía Ticio [delegante], ¿me los darás tú? [delegado]".

- * En realidad, la *delegatio* significa una novación cuando hay una obligación precedente que se transforma por cambio del acreedor o del deudor; pero puede darse el caso de *delegatio* sin obligación precedente, como cuando el delegado efectúa el negocio queriendo hacer un favor o una donación al delegante. En estos casos no habría novación.

Efectos de la novación. — Podemos establecer en general que los efectos, tal como se dice en la definición, son dos: extinguir la obligación antigua y crear una obligación nueva.

(A) Respecto de la obligación primera, se produce la extinción *ipso iure*, así como también de todos sus accesorios —fianzas, hipoteca, prenda y también los intereses—, salvo que se hubiera previsto especialmente su vigencia en la nueva.

- * En el caso de cambio del deudor, como la primera obligación queda extinguida, el acreedor no podrá ir contra el primer deudor en caso de insolvencia del segundo. Para poder prevenirse de este riesgo debía ya establecerlo como condición de la novación —por lo cual la convertiría en condicional—, ya hacerse dar por el primer deudor un mandato —teniendo en ese caso la posibilidad de la *actio mandati* con *transcriptio*— para lograr una indemnización del perjuicio derivado de la novación.

(B) Respecto de la obligación nueva, ésta comienza a regir en los términos estipulados por las partes.

- * Si la *stipulatio* novatoria llega a ser nula —por ejemplo, si fuera realizada por el pupilo sin la *auctoritas* del tutor—, de todos modos la primera obligación queda lo mismo extinguida.
- * En la obligación nueva sólo podrán interponerse las excepciones que hubieran correspondido a la primera si en la *stipulatio* novatoria se hubiera dejado constancia de la causa negocial: así, "los 100 que debías por la compraventa..."; pero no si sólo se hubiera dejado mención del objeto: así, "los 100 que debías...".

Casos especiales de novación. — Dos merecen destacarse.

(A) La *litis contestatio* * —ya tratada en el análisis del procedimiento— provocaba la extinción de las obligaciones civiles demandadas en un *iudicium legitimum*, las que se transformaban en la "relación procesal" establecida en la fórmula. Técnicamente no sería una *novatio*, pero los autores romanos clásicos asimilaron sus efectos.

87 504 1

86

(B) La *stipulatio Aquiliana*. Tomaba su nombre del jurista Aquilio Galo —pretor en el año 66 a.C.—, quien sugirió esta fórmula para resolver los problemas que acaecían con obligaciones muy confusas, al convenir las partes la novación de las mismas por medio de una *stipulatio*.

- La fórmula empleada era así: "Todo aquello que me debes o deberías por cualquier causa dar o hacer en la actualidad, a término o bajo condición; cualquier cosa por la cual tengo o tendría yo contra ti, acción, petición o reclamación; cualquier cosa mía que tú hagas o poseas, o que por dolo malo has dejado de poseer; tanto cuanto vale cada una de estas cosas, otro tanto ha estipulado Aulo Agerio que le sería dado en dinero, y a ello se ha comprometido Numerio Negidio". Tenía, pues, las características de una transacción judicial.
- La forma de extinguir esta *stipulatio Aquiliana* era la *acceptilatio*.

MUTUO DISENSO

La obligación que ha sido contraída por el *consensus* —en un contrato consensual— podía ser extinguida por un *contrarius consensus* —es decir, por un convenio contrario.

- El *mutuus dissensus* (mutuo disenso o contrario consentimiento) parece ser que se generó en la compraventa, debiendo ocurrir antes de que una de las partes realizase la prestación.
- Posteriormente se extendió a la *locatio conductio*. En la sociedad y en el mandato no era necesario el mutuo disentimiento, dado que en ellos la voluntad de una sola de las partes podía dar por finiquitado el contrato.

CONCURSO DE DOS CAUSAS LUCRATIVAS

Cuando alguien ha adquirido por una causa gratuita —se la llama *causa lucrativa*— una cosa que le era debida por otra "*causa lucrativa*", esta segunda obligación queda extinguida *ipso iure*, sin intervención de la voluntad de las partes.

- Así, por ejemplo, si recibo por donación una cosa que me sería debida por un legado, la obligación nacida de este último se extingue.
- La necesidad de que las causas de adquisición fueran gratuitas surgió quizá con Juliano. Anteriormente no importaba si una era gratuita y la otra onerosa. En cambio, después se determinó que en ese supuesto —por ejemplo, si he comprado la cosa que me era debida por legado— se podía accionar por el monto del valor de la cosa.

CONFUSION

Existe confusión (*confusio*) cuando por cualquier circunstancia concurre sobre la misma persona la condición de acreedor y de deudor.

- Así, por ejemplo, cuando una persona hereda a otra, respecto de la cual era deudora o acreedora.

MUERTE Y CAPITIS DEMINUTIO

En ciertos casos, la muerte de uno de los sujetos puede determinar la extinción de la obligación.

- Esto se da con especiales características en las obligaciones delictuales; también en la sociedad* —muerte de uno de los socios— y en el mandato —muerte del mandante o mandatario.

Del mismo modo, la *capitis deminutio** puede determinar la extinción de las obligaciones.

- Incluso ocurre con la *capitis deminutio minima*; verbigracia, en el caso de la adrogación* —extinción de las deudas de quien se da en adrogación— y también en la *conventio in manu** de una mujer *sui iuris*.

fg

MODOS DE EXTINCIÓN OPE EXCEPTIONIS

COMPENSACION

Ocurre la compensación (*compensatio*) cuando un deudor opone a su acreedor un crédito que tiene contra éste, de tal modo que los créditos y las deudas se contribuyen entre sí.

I. La compensación aparece en el derecho clásico como una vía procesal —más que como medio autónomo— por la cual el pretor, en ciertas circunstancias, concederá al demandado por un crédito no extender la acción contra él dirigida más allá del monto por el que el actor estuviese a su vez obligado ante aquél, pudiendo en consecuencia progresar la demanda sólo de existir un saldo a favor del actor.

(A) Ello ocurrirá en el supuesto de los *iudicia* o *actiones bonae fidei**, en los cuales el *iudex* podrá tener en cuenta estas recíprocas pretensiones, adecuando numéricamente el saldo en la sentencia.

(B) Se admitía este modo también para los banqueros (*argentarii*), quienes podían demandar a sus clientes sólo por el saldo que resultase de la deducción de los contracréditos que les pudiesen oponer éstos.

(C) También el comprador de los bienes en una *bonorum venditio** —es decir el *bonorum emptor*— debía demandar al deudor de la masa de bienes haciéndole deducción de lo que le debía el concursado.

II. Un paso importante en la historia de la compensación se logró por un rescripto del emperador Marco Aurelio, quien extendió el ámbito de la misma a las *actiones stricti iuris**. El modo utilizado fue muy simple, por cuanto permitió que el deudor demandado que pudiera oponer una compensación adujera una *exceptio** *doli*.

* La inserción de la *exceptio doli* le daba libertad suficiente al juez para hacer jugar la compensación. Si el crédito del demandado era mayor o igual al del actor, correspondía absolverlo; si era de un valor inferior, lo condenaba solamente por el saldo.

III. Finalmente, en la época de Justiniano, la compensación se erige con mayor autonomía respecto del procedimiento. Esto fue debido a la suplantación del procedimiento formulario por *extra ordinem cognitio**.

Se le admitió como modo de extinción *ipso iure*, lo cual ha provocado algunas controversias. Para que se pudiera operar comenzaron a establecerse ciertos requisitos.

(A) La identidad de personas entre el acreedor y el deudor recíproco.

(B) Que los objetos compensados fueran homogéneos, es decir fungibles entre sí. Generalmente tenía lugar cuando se trataba de dinero.

(C) Que los créditos fueran exigibles, pues no se podría compensar un crédito que fuera puro y simple con otro sometido a un plazo o a una condición.

(D) Que los montos de las prestaciones fueran líquidos, es decir, fácilmente determinables en la cantidad.

* El problema sobre el carácter de *ipso iure* de la compensación residía en que para algunos glosadores dichas palabras debían interpretarse en el sentido de que la compensación se operaba directamente por la ley, es decir, aun cuando no la opusiera el demandado. En cambio, parece prevalecer hoy día que el vocablo *ipso iure* en la constitución de Justiniano debe interpretarse como que el juez no debe acudir más a medios indirectos —como la *exceptio doli*—, bastando el mero planteo del demandado.

REMISION DE LA DEUDA

Ocurre la remisión de la deuda cuando el acreedor se compromete por medio del *pactum de non petendo* (pacto de no reclamar) a no exigir el cumplimiento de la obligación.

88

504 1

87

- El *pactum de non petendo* permite, en caso de incumplimiento, el ejercicio de la *exceptio pacti conventi*.
- En la época de Justiniano se distinguen dos clases de *pactum de non petendo*, ya que puede ser *in personam* —cuando el perdonado es sólo el deudor— o *in rem* —cuando abarca también a los herederos, fiadores, deudores solidarios, etcétera.

TRANSACCION

Ocurre la transacción (*transactio*) cuando las partes, haciéndose recíprocas concesiones o renunciando, deciden poner fin a obligaciones dudosas o litigiosas.

- La transacción tiene el carácter fundamental de finiquitar problemas judiciales, por lo que por lo común tiene lugar mediante la renuncia a la *actio* por parte del actor, a cambio de una contraprestación por parte del demandado.
- La forma adoptada es la del pacto. Por ello, en principio no da origen a una acción, sino que genera excepciones: así, la *exceptio pacti conventi*, o en general la *exceptio doli*.
- Más tarde puede recurrirse a transar mediante una *stipulatio* —por ejemplo, por la *stipulatio Aquiliana*—, en cuyo caso tendría la *actio ex stipulatu*. Justiniano la distinguirá del pacto, estableciéndola entre los contratos innominados², por lo que para su cumplimiento se contaba con la *actio praescriptis verbis*.

PRESCRIPCION LIBERATORIA

En el derecho bizantino, y debido a una constitución del emperador Teodosio II, se determinó que, salvo casos especiales en que se establezca otro plazo, todas las acciones fenecen si no se las ejercita en el plazo de treinta años (*praescriptio triginta annorum*).

- En un principio, en Roma, la regla general era que las acciones civiles fueran "perpetuas". Este principio no se aplicaba a las acciones de origen pretoriano, estableciéndose acá que la mayoría de ellas se extinguía al año, si bien

- había muchas dificultades para saber cómo se calculaba el año, es decir, si era "continuo" o se computaba solamente el tiempo "útil", descontándose aquellos días en que el que se proponía accionar estaba impedido por algún obstáculo. Al parecer prevaleció esta última opinión.
- Había algunos casos en los cuales el plazo era mayor a los treinta años fijados por Teodosio II. Así, la prescripción de 40 años para la hipoteca y para los créditos debidos a la Iglesia e instituciones pías y la de 50 años para repetir lo pagado por juegos prohibidos. El crédito del fisco era imprescriptible.
 - El nombre deriva de la parte de la fórmula —*praescriptio*— y obviamente significaba, de manera indirecta, la extinción de la obligación, al impedir su ejecución.

CAPITULO XIII

FAMILIA

Si en materia patrimonial el derecho de hoy en día sigue en lo fundamental las pautas institucionales del Derecho Romano, en lo referente a las relaciones de familia se notan cambios trascendentes entre las modernas instituciones que conservan el nombre romano de patria potestad, familia, tutela, matrimonio, etcétera, pero que obedecen a valoraciones y condicionamientos muy distintos a los primitivos de la comunidad romana. Aun en el mismo seno de ésta ningún otro sector del quehacer jurídico tuvo una más profunda evolución que la normativa de las estructuras y relaciones familiares. Ningún otro estuvo tan sometido, no sólo a la gravitación de los factores económicos y sociales sino también a los éticos e ideológicos: valga como ejemplo la enorme transformación producida en las concepciones y regímenes familiares por el cristianismo.

CONCEPTO DE FAMILIA

El vocablo familia aparece aquí con varios significados.

I. Familia *proprio iure dicta* (llamada de derecho propio) es el conjunto de personas libres que se encuentran bajo el poder de un *paterfamilias*.

II. Es también familia —*communi iure dicta* (llamada de derecho comunitario)— el complejo de personas libres que se hubieran encontrado sometidas al poder de un mismo *paterfamilias*, antepasado común, si éste estuviera con vida todavía.

III. También *familia* aparece en algunos textos para indicar ese conjunto de personas que creó descender de un mítico

antepasado común —bajo cuyo poder estarían, de vivir todavía— que ya se ha estudiado bajo el nombre de *gens* *.

IV. También con el nombre de familia se alude al conjunto de cosas sujetas al poder de un *paterfamilias* y que forman una masa patrimonial o hereditaria: se habla así de la *actio familiae erciscundae* * o del *familiae emptor* *.

V. Hasta se usa familia para referirse al conjunto de todos los esclavos sometidos al dominio de un *paterfamilias*.

El común denominador de todos estos significados está dado por el sometimiento al poder de un *paterfamilias*: ese es el pivote alrededor del cual se estructura cada uno de esos aludidos complejos de personas o cosas organizados jurídicamente como un todo, como un *corpus*.

- * De aquí en adelante es el primero de los significados de familia el que nos ocupará especialmente: el de las personas libres que a un tiempo están efectivamente sometidas al poder de un *paterfamilias*.
- * La expresión latina *paterfamilias* significó primitivamente algo así como jefe de la casa. En efecto, la palabra *pater* no estaba vinculada con la idea de progenitura sino con una raíz que significaba poder, fuerza, y la palabra *familia* indicaba lo perteneciente al sitio donde se vive, el hogar, la casa. Etimológicamente, *paterfamilias* tiene el mismo origen que el vocablo griego *despotes*, de donde procede nuestra palabra déspota.

Jurídicamente, *paterfamilias* es el varón libre y ciudadano que no tiene ascendiente varón vivo —o que ha sido emancipado por el que tiene— y que no ha sido sujeto por adopción o adrogación a la potestad de un extraño. Ser un *paterfamilias* —al margen de que se esté realmente a la cabeza de un concreto grupo familiar— es tener un *status* personal de *sui iuris*, es decir, tener capacidad jurídica tanto en la esfera del derecho público como en la del derecho privado.

- * Se es *paterfamilias* —siempre que se cumplan esas condiciones— aunque se sea un impúber o se esté eventualmente sujeto a curatela. Se trataría, en estos casos, de una incapacidad de actuar y no jurídica.
- * En cambio, a la mujer *sui iuris* —aunque sea a veces designada *materfamilias*— no se le reconoce, por lo menos en el período clásico, ningún

poder sobre personas libres: por el contrario, estuvo sujeta a la tutela^o dispensada por razón de sexo.

Las personas libres que pueden estar sujetas —*alieno iuri subiectae* (sujetas a otro poder) o *alieni iuris*— son los *filiifamilias*: hijos varones o mujeres y los descendientes por vía masculina —siempre que sean legítimos, es decir, concebidos en *iustae nuptiae*—; los extraños adoptados o adrogados; las mujeres que, al casarse con el *paterfamilias* o con hijos legítimos o adoptivos de éste, lo hubieran hecho con *conventio in manum**, y se encuentran, por lo tanto, *loco filiae* (en lugar de hija) o *loco nepotis* (en lugar de nieta), respectivamente.

AGNACION Y COGNACION

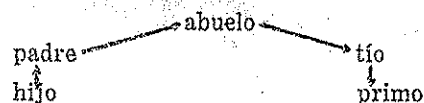
En efecto, el vínculo de parentesco por el que se estructuraba la familia romana de los primeros tiempos era exclusivamente la agnación, y ésta se daba entre todos aquellos que hubieran estado sujetos al poder de un individualizado *pater*, considerado origen “cierto” de la familia, si éste, hipotéticamente, hubiera seguido viviendo [ver gráfico]. Se caía bajo la potestad de un *pater*: a) o por haber sido concebido en legítimo matrimonio del *pater* o varón a él sometido; b) o por ser adoptado por el *pater*; c) o, en el caso de una mujer, como consecuencia de nupcias con el *pater* o varón a él sometido. Resultaba así que el vínculo agnático se transmitía solamente vía masculina. Quedaba entonces establecido un exclusivismo familiar: como únicamente se podía estar sujeto a una potestad, sólo se podía pertenecer a una familia y se era, por tanto, absolutamente extraño a la familia propia de la madre; la relación de consanguinidad entre el abuelo materno y sus nietos no producía parentesco porque éste era exclusivamente con base en la sujeción a la potestad de un *pater*.

Ese vínculo de la consanguinidad, la cognación, sólo con el tiempo fue adquiriendo relevancia jurídica, y habrá que esperar a Justiniano en el siglo VI a.C. para que desplace total y francamente el principio agnático, que hasta ese entonces había estructurado formalmente el sistema familiar romano.

AB

PARENTESCO

La relación de parentesco se mide por grado. Entre ascendientes y descendientes en línea recta hay tantos grados como generaciones: un grado entre padre e hijo, dos entre abuelo y nieto, etcétera. En la línea colateral, el grado de parentesco entre dos personas se mide computando las generaciones que van de una de ellas hasta el ascendiente común, y las que van desde éste hasta la otra persona: entre primos, el parentesco es de cuarto grado, pues hay que remontarse dos generaciones hasta el abuelo común y bajar luego otras dos.

PANORAMA HISTÓRICO DEL
RÉGIMEN FAMILIAR

El estado político-social en el Lacio, anterior a la génesis de Roma, parece haber estado constituido por la existencia de esos grandes grupos parentales que hemos estudiado bajo el nombre de *gentes*. Cuando la *civitas* fue tomando para sí las funciones políticas de las *gentes*, éstas fueron perdiendo vigencia y de ellas fueron resultando agrupamientos familiares que en su estructura denotaban todavía aquel carácter político de las primitivas *gentes*.

Era tan fuerte la unidad de la familia romana —tanto en la agnaticia como en la *proprio iure* de los tiempos históricos—, tan absoluto el poder del *pater* sobre personas y cosas, que ya los mismos romanos tenían cabal conciencia de que se distinguían en eso de los otros pueblos del mundo mediterráneo. Y en tiempos modernos se ha fundado —especialmente por Bonfante— la teoría del origen y carácter político de esa institución en argumentos que pueden sintetizarse como sigue a continuación.

(A) Existe una desproporción entre la fuertemente autoritaria estructura de la familia y las normales funciones de índole social y económica que desempeñó en la época histórica.

(B) Muchos institutos de derecho privado romano presentan tales modalidades políticas que parecen haber estado dirigidos primordialmente para llenar funciones de orden y gobierno y que sólo con el transcurso del tiempo llegaron a perseguir objetivos patrimoniales: el testamento y la tutela, por ejemplo.

(C) La autonomía del *pater* en el manejo de la familia rechaza cualquier ordenamiento o injerencia externa.

(D) Se pertenece exclusivamente a una familia, como a un solo estado.

(E) El parentesco —agnación— se establece por situación de sometimiento a la autoridad de un *pater*. La misma palabra *agnatus*, si bien está compuesta por la raíz que significa nacer, no alude al vínculo de sangre.

(F) El carácter absoluto, originario y unitario de la *manus* recuerda el *imperium* de los supremos magistrados.

(G) Los poderes del *pater* son similares a los correccionales y jurisdiccionales del magistrado romano.

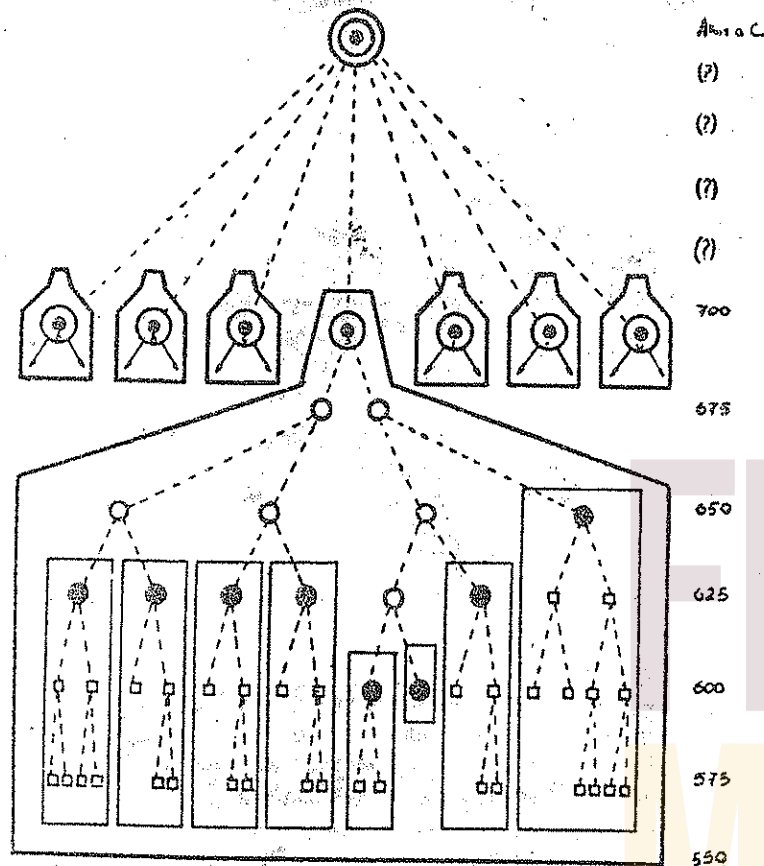
(H) El derecho de propiedad (*dominium*) evoca, por lo absoluto, perpetuo y exclusivo, la soberanía estatal, y sus formas se explican por razones políticas, no sociales y económicas.

(I) El testamento *calatis comitiis* es la designación por el *pater* de su sucesor en el gobierno familiar, lo que resulta paralelo con la atribución reconocida por el derecho público romano al magistrado de designar o proponer a su sucesor.

I. Antes del tipo de familia llamado *proprio iure*, que es el que tiene vigencia por lo menos desde la ley de las XII tablas y, con algunas atenuaciones, hasta Justiniano, habría existido la llamada *communis iure* o familia grande o agnaticia, llamada así porque habría comprendido a todos los agnados.

Ya la hemos definido como el conjunto de personas libres que en razón de una bien determinada descendencia por vía masculina a partir de un antepasado común estaría, de vivir éste, sometida a su patria potestad.

Así, representa en pleno período histórico un esquema ideal, referible sólo para identificar el vínculo de agnación: pero en



OBSERVACIONES

Todos los que aparecen en el gráfico y los descendientes de A, B, C, E, F y G —representados por las flechas y omitidos por razones de espacio— son gentiles, pertenecen a la misma gens.

Se indican solamente varones pues sólo por vía masculina se determina y transmite el parentesco agnaticio, el único jurídicamente relevante en la época estudiada.

Se ha calculado un intervalo de 25 años para cada generación.

- Antepasado presunto o pretendido con el cual las líneas de parentesco o son vagas o se confunden en el tiempo.
- Antepasado a partir del cual los vínculos están claramente determinados.
- Pater ya fallecido para el año 550 a.C.
- Pater en el año 550 a.C.
- Hijo de familia — es decir sometido a patria potestad — en el 550 a.C.
- Familia *proprio iure*.
- Familia agnaticia — comprendiendo en el gráfico también a los miembros fallecidos ya para el año 550 a.C.—

tiempos prehistóricos —antes del testimonio escrito— la familia agnaticia habría sido un grupo real unido efectivamente por la sujeción a la potestad de un *pater*, que habría recibido la jefatura de una serie de sucesivos *patres* —que a su tiempo la ejercieron vitaliciamente—, serie iniciada, precisamente, con aquel antepasado común.

Su diferencia con la familia romana de los tiempos históricos consiste en que, en el sistema de la familia agnaticia indoeuropea, a la muerte del *pater* la familia seguía permaneciendo unida bajo el poder de un sucesor —designado por primogenitura, por elección de sus iguales o, en Roma, por voluntad del extinto jefe—, en tanto que en la familia *proprio iure*, al desaparecer el *pater*, todos los varones que estaban bajo su inmediata patria potestad adquirían condición automática de *patres* y se convertían cada uno en cabeza de una nueva familia.

II. Convendrá ahora esquematizar la estructura y las denotaciones de esos tres grupos parentales a que se ha aludido.

Como puede verse en el gráfico, una gens está compuesta por varias familias agnaticias. También se desprendería que varias —ocho en el gráfico— familias *proprio iure* formarían una familia agnaticia, pero téngase en cuenta que esto es sólo válido como esquema, mas no en la realidad institucional de una época determinada. Es decir, en el Lacio del siglo VIII a.C., por ejemplo, no habrían existido todavía familias *proprio iure*, pues, en esos tiempos —que suponemos de plena vigencia de la familia agnaticia— todos los que en el gráfico aparecen como *patres* no lo serían, con la excepción de uno, y estarían sometidos a la potestad de ese uno precisamente; en la época histórica, en cambio, todos ellos serían, cada uno, cabeza soberana de una exclusiva y hermética familia; no habría ninguna familia agnaticia, si bien los miembros de las ocho familias *proprio iure* serían agnados entre sí, con las consecuencias jurídicas que se verán más adelante.

III. Claro que entre la época de la familia agnaticia y la de la familia *proprio iure* ha habido toda una evolución de la organización familiar, una compleja y no uniforme descomposición de la familia grande en grupos menores que la integraban, hasta

que quedó perfilada la unidad de la familia romana de los tiempos históricos.

Conjeturemos primeramente un perfilamiento de las familias agnáticas dentro de la *gens* y luego la disgregación de aquellas en familias *proprio iure*. En los tiempos históricos, sabemos, sólo quedaron de la *gens* unos pocos vestigios de rápidamente decreciente relevancia jurídica y de la familia agnática el vínculo de agnación, que, como hemos visto, conformó, aunque también con importancia decreciente, la organización familiar romana hasta Justiniano.

IV. En plena vigencia de la familia *communi iure* existiría un patrimonio familiar permanente o eterno, como lo era la familia, prolongada desde los antepasados y proyectada hacia los futuros descendientes. De ese patrimonio, los actuales integrantes de la familia tendrían una especie de usufructo y el *pater*, no una propiedad individual, sino un poder de disposición gerencial, ejercido como titular de la única capacidad jurídica plena reconocida en una comunidad integrada por grupos y no por individuos.

El testamento *calatis comitiis** e *in procinctu** habría sido el acto político —por eso, celebrado ante los conciudadanos— mediante el cual el *pater* designaba al sucesor en la jefatura. La familia *communi iure* se mantenía unida a través de esa única jefatura, prolongada de generación en generación.

Cuando creada la *civitas* se agudizaron las transformaciones que se asocian con la llamada revolución urbana —división y especialización del trabajo, agricultura intensiva, artesanía y comercio con su exigencia de libertad de iniciativa individual, aparición de las clases sociales, de los órganos especificados de gobierno, etcétera—; cuando el desarrollo de la esclavitud trajo la posibilidad de concentración de mano de obra; cuando una más amplia y unitaria organización política no basada ya en el parentesco, fue quitando la razón de ser de los grandes grupos parentales de finalidad y estructura política, la familia agnática, propia de una economía de autoabastecimiento y de una sociedad no integrada plena y funcionalmente en estructuras po-

líticas suprafamiliares, entró en crisis y se desgajó en grupos familiares más chicos y más ágiles para una sociedad de mayor diversificación e intercambios económicos.

V. La institución por la que, en nuestra opinión, se habría vehiculado la transición de un tipo de familia a la otra fue el llamado *consortium ercto non cito* (comunidad de heredad no dividida).

Sea que el *pater* se despreocupó de asegurar una jefatura única para su grupo, sea que el aspecto económico patrimonial fuera adquiriendo mayor relevancia, cada uno de los que había estado bajo la inmediata potestad del *pater* fallecido, sin perjuicio de reconocer una primacía política y moral al nuevo *pater* si éste había sido designado, se sintió con derechos al manejo en común del patrimonio familiar, se sintió *consors* y *sui iuris*.

Esa sería la situación inmediatamente anterior a la época de la ley de las XII tablas: tal vez un *pater* único con ascendiente moral, religioso y político —tutelas y curatelas— y el *consortium* —ya analizado cuando se trató del condominio— titulariado por los *sui iuris* del grupo.

VI. El próximo paso hacia la familia *proprio iure* se habría dado en la época de la ley de las XII tablas al reconocer ésta el derecho de cada uno de esos *sui iuris* a conseguir con la *actio familiae erciscundae* la parte concreta correspondiente a la cuota ideal que titulariaba en el *consortium*. Entonces, ya ese *sui iuris* sería un *paterfamilias* con el efectivo dominio de ese patrimonio propio desgajado del *consortium* y con poder efectivo potencial sobre sus *filiifamilias*.

VII. Pero también la familia *proprio iure*, fuertemente estructurada sobre la sujeción al poder del *pater* y la exclusiva capacidad jurídica reconocida a éste, irá sufriendo cambios en la vida real que no se institucionalizarán sino poco a poco y sin afectar formalmente los principios básicos.

Ello naturalmente debido a transformaciones económicas, sociales y religiosas que llevan, en el plano psicológico, a representarse a la familia, no tanto como una entidad trascendente, sino como un conjunto de individualidades.

Así, ya desde la ley de las XII tablas será posible la salida

91

504 1

del grupo familiar de cualquiera de los *filiifamilias* para constituir otra familia —emancipación*— o ingresar en otra —adopción*—; se podrá evitar que la mujer casada ingrese en la familia del marido —*trinctium**—; las cosas del patrimonio —antes familiar, ahora individual del *pater*— serán todas enajenables; el *pater* podrá testar en favor de extraños sin incorporarlos previa o simultáneamente a la familia...

VIII. Más adelante, por la creciente injerencia del estado, que reclamaba para sí el poder punitivo, irán sufriendo fuertes limitaciones los poderes personales del *pater*, y, por las necesidades de una sociedad más diversificada e individualista, se verá afirmada, paulatinamente, la capacidad de los *filiifamilias* en el manejo patrimonial a través de la institucionalización de la práctica del *peculium*.

Pero el más ilustrativo cambio estará en la creciente relevancia jurídica del parentesco de la sangre —cognación—, prevaleciendo sobre el parentesco civil —agnación—, que dejará, en la época justiniana, de estructurar la familia y fundamentar la vocación hereditaria *ab intestato*.

LOS PODERES DEL PATERFAMILIAS

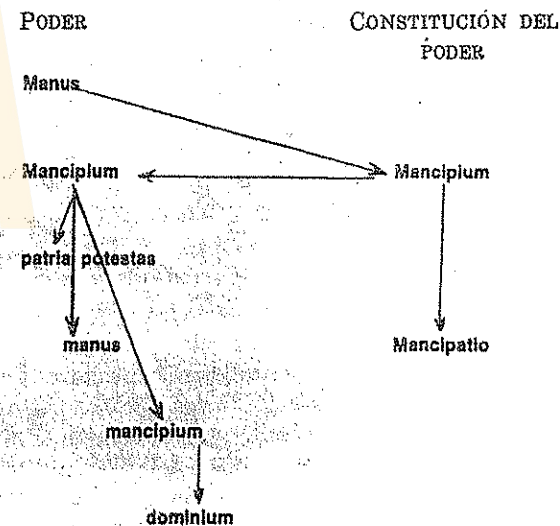
Lo que para nosotros sería una suma de derechos, facultades, atribuciones, prerrogativas que correspondían a los *patres* como jefes de los grupos, era vivenciado por ellos como un poder unitario, absoluto, sin fisuras, sin matices, simplemente el poder...

I. Ese poder parece haber sido designado, con simple concretez, con la palabra *manus* (mano), que por extensión de la idea de posibilidad de manejo o aprensión habría llegado a significar poder, como cuando nosotros decimos "está en mis manos hacer esto".

Con posterioridad debe de haberse plasmado la palabra compuesta *mancipium* —de *manum capere* (tomar, retener el poder)— con el significado de adquisición y detención de la *manus*. *Mancipium* vino tanto a designar el acto al que se recurría precisamente para la constitución de la *manus* sobre las

cosas o personas, como a suplantar —tal vez por su mayor expresividad específica— a *manus*. Al fin y al cabo, existir un poder —*manus*— equivale a existir una detentación de poder —*mancipium*—. Con el tiempo, en la medida en que una sociedad más compleja y una elemental reflexión sobre las experiencias jurídicas iban perfilando distintos objetos, aspectos y modalidades de aquel poder, vivenciado al principio como simple y unitario, habríase originado una correlativa especificación en las denominaciones: el poder sobre los *liberi* —los libres, los descendientes, en oposición a los esclavos— será *patria potestas*; el poder sobre la mujer, ingresada al grupo por casamiento, será la antigua *manus*; el poder temporario sobre *alieni iuris* de otras familias entregados *in causa mancipi** mantendrá para siempre aquel nombre de *mancipium*; el poder de disposición sobre las cosas y los esclavos, que equivale a nuestro concepto de propiedad, siguió también manteniendo aquella denominación hasta el siglo I a.C., en que comenzó a usarse *dominium*.

Una palabra derivada de *mancipium* la suplantó en su referencia al acto constitutivo del poder: *mancipatio*.



PATRIA POTESTAD

Los romanos tenían perfecta conciencia de que la patria potestad era un *ius proprium romanorum* (derecho peculiarísimo de los romanos), por su carácter tan absoluto y vitalicio, no conocido en ningún otro pueblo.

Originariamente, la patria potestad —como la *manus*, a ella asimilada— importaba poder y no deberes ni obligaciones hacia los sujetos a ella. Pero a través de restricciones y cargas —como la obligación de prestar alimentos— llegará a ser considerada un *officium* (deber) de asistencia y protección.

De todos modos, la patria potestad justinianeas sigue diferenciándose de la moderna en: (A) corresponde al varón y no a la mujer; (B) incumbe al ascendiente más remoto y no al progenitor y (C) es permanente, pues no cesa a determinada edad del a ella sometido.

Comprendía, especialmente, el *ius vitae ac necis* (derecho de vida y muerte); el *ius exponendi* (derecho de exposición o abandono); el *ius vendendi* (derecho de vender); el *ius noxae dandi* (derecho de entrega noxal).

- El *ius vitae ac necis* no tenía otra limitación que la propia conciencia y afectos del *pater* y la opinión pública que podía institucionalizarse en una *nota censoria* ante notorios abusos. Pero, a comienzos del Principado, aisladas resoluciones de los emperadores comienzan a restringirlo y a castigar las demasías, pero sin llegar a considerar delito de homicidio a su ejercicio. Por influencia cristiana, Constantino castiga con la misma pena del parricidio a quien dé muerte a su hijo; Valentiniano castiga con pena capital la supresión de los recién nacidos. Justiniano sólo reconocerá al *pater* un poder de disciplina y corrección.
- Se acostumbraba depositar al recién nacido a los pies del *paterfamilias* —no necesariamente el padre de la criatura—; al levantarlo (*tollere liberum*) lo incorporaba al ámbito de su patria potestad. Si no lo hacía, se consideraba a la criatura expuesta, abandonada. Quien lo recogía podía darle condición de libre como *alumnus* (el que es alimentado) o de esclavo. Pero Justiniano decidió que en principio todo niño expuesto fuera considerado libre.
- Lo que en la ley de las XII tablas y aun en la época clásica se significaba con el verbo vender —a propósito de un *filiusfamilias*—, es, en realidad, entregarlo *in causa mancipii* *. Sólo en los tiempos difíciles de las crisis económicas del Bajo Imperio se admitió, retrogradamente, que el hijo vendido deviniera esclavo del adquirente.

Justiniano lo permitió en casos de extrema pobreza del *pater* y con la

posibilidad de que el vendido pudiera rescatarse por el mismo precio por el que habría sido adquirido.

- También para el *pater*, la entrega noxal del *filius*, para no ser responsable del delito por éste cometido, habría consistido en darlo a través de una *mancipatio*, no como esclavo de la persona damnificada, sino *in causa mancipii*. Esta facultad de la patria potestad fue abolida por Justiniano como contraria al nuevo trato de los hombres (*nova hominum conversatio*). Además, ya la capacidad y correlativa responsabilidad patrimonial de los *filiifamilias* había sido reconocida: la institución abolida ya no tenía razón de ser.

MODOS DE ENTRAR EN LA FAMILIA

Son *aut natura aut iure* (o por naturaleza o por derecho).

Se ingresa *natura* en la familia por haber sido engendrado en *iustae nuptiae* (matrimonio de acuerdo al *ius*) del *pater* o de cualquiera de los *filii* a él sujetos.

Se ingresa *iure* por medio de la adrogación, la adopción y la *conventio in manum*.

FILIACION

Es el vínculo de procreación del que se derivan ciertos efectos jurídicos. Es legítima si tiene lugar en *iustae nuptiae*: los procreados son entonces *iusti*. Es natural cuando tiene lugar fuera del matrimonio. Los hijos se llaman entonces *spurii* (espurios) o *vulgo concepti* (concebidos al azar). La calificación de naturales se usa (A) refiriéndose a los *iusti*, para diferenciarlos de los adoptivos, (B) o para aludir a los nacidos de concubinato.

I. En el antiguo *ius civile* no existe un recurso jurídico para desconocer o hacer reconocer la legitimidad de los hijos: recuérdese que el *pater* tenía el *ius exponendi* * y que por lo absoluto de su soberanía no podía pensarse en obligarlo a aceptar contra su voluntad el ingreso de alguien en su familia.

II. De todos modos, el problema de la legitimidad se resuelve constatando la validez del matrimonio y la concepción durante éste: el hijo nacido no antes de transcurridos 180 días desde aquél en que se inició el matrimonio y no después de 300

92

504 1

91

días de disuelto, se presume engendrado por el marido y por lo tanto es legítimo. La presunción es *iuris tantum*, es decir, admite prueba en contrario.

III. También por legitimación entran bajo la patria potestad del padre natural los hijos habidos de la concubina.

- * En la época clásica se acostumbraba a adrogarlos, pero a partir de Constantino la legislación, de inspiración cristiana, permitió legitimarlos *per subsequens matrimonium* (a través de un subsiguiente matrimonio) con la concubina, madre de los hijos en cuestión. Institución que recoge Justiniano junto con la prohibición de adrogar hijos naturales.
- * También sobre precedentes posclásicos, inspirados por necesidades fiscales, se permitió legitimar *per oblationem curiae* (por oblación a la curia). Se le daba al hijo —por donación o testamento— un patrimonio suficiente para cubrir las *munera** propias de los decuriones*. A la hija, para legitimarla de este modo, debía darse una dote que diera igual posibilidad a su marido. Esta legitimación sólo tenía relevancia respecto al progenitor, no al resto de su familia.
- * En el derecho justinianeo se pudo legitimar *per rescriptum principis* (por medio de un rescripto imperial) cuando no era posible *per subsequens matrimonium* —por ejemplo, por muerte de la concubina— y no se tenían hijos legítimos.

ADROGACION Y ADOPCION

Entran a la familia los extraños que en virtud de la adrogación —si se trata de un *sui iuris* o *pater familias*— o de la adopción —si es un *alieni iuris*— pasan a estar sujetos a la patria potestad del *pater*.

- * Ambas instituciones llegaron a ser muy practicadas en Roma, pues —fuera de las sentimentales que puedan existir hoy en día— había fuertes razones religiosas, sociales y políticas para asegurar la continuidad de la familia y del culto privado.

La adrogación —practicada ya antes de la ley de las XII tablas— permitía al *pater* sin posibilidades de dejar un hijo varón al frente de la familia, procurarse uno, haciendo ingresar a ella a otro *pater*. En los primeros tiempos se recurría a un solemne acto político, frente a los comicios curiados presididos por el pontífice máximo, que debía hacer presente la aquiescencia del colegio a la adrogación. Según Gayo, se llamaba *adrogatio* porque eran objeto de *rogatio* (interrogación) el adrogante, el adrogado y también el pueblo, con lo que todos habrían debido

así, expresar su consentimiento. Aprobada la adrogación, tenía lugar la *detestatio sacrorum* (abandono de los ritos del culto familiar) hecha por el adrogado, cuya familia se insumía en la del adrogante.

Por constituciones imperiales se estableció para el resto del imperio la adrogación *per rescriptum principis*, la que —después de haber sustituido la tramitada ante el comicio curiado en Roma— quedó, única, en la legislación justiniana.

Para entonces ya se había extendido la posibilidad de ser adrogados a los impúberes y a las mujeres —toda vez que éstas no tenían ya que presentarse ante los comicios curiados, a los que nunca habían tenido acceso.

Los requisitos para la adrogación son congruentes con su finalidad y con el objeto de evitar torpes maniobras: más de 60 años y ningún hijo en el adrogante; sólo un adrogado; no ser éste más rico que aquél; garantía de restitución del patrimonio del adrogado a quien hubiere correspondido en el caso de que aquél hubiese muerto *sui iuris* e impúber; igual garantía para el adrogado en el caso de ser emancipado antes de la pubertad; derecho del adrogado a un cuarto de los bienes del adrogante, si éste lo emancipara sin *iusta causa*.

La adrogación produce la *capitis deminutio minima* del adrogado, que resulta ahora *alieni iuris*, asimilado a un *filius* del *pater*. Produce también una de las sucesiones a título universal *inter vivos*, toda vez que el patrimonio y la familia del adrogado pasan a ser adquiridos por el adrogante. Como a éste no le correspondía quedar obligado por las deudas del adrogado, el pretor admitió la acción *de peculio* y la *in integrum restitutio* para considerar no sucedida la adrogación y actuar entonces contra el adrogado.

La adopción significa el egreso de un *alieni iuris* desde una familia y el ingreso a la del adoptante. Institución no antigua, cuando se hizo necesaria, se instrumentó sobre otras ya existentes: para hacer salir al adoptado de la patria potestad a que estaba sometida se recurrió al mismo procedimiento de la emancipación, tal como estaba sugerido por aquella disposición de la ley de las XII tablas: si *pater filium ter venum duit, filius a*

pater liber esto (si el padre da en venta [*in causa mancipi*] tres veces a su hijo, éste queda libre de aquél).

- * La mayoría de los que han comentado esta norma la han interpretado como un límite al derecho del *pater* de disponer de sus hijos y como una compensación para el hijo que ha sufrido tres *mancipationes*. Creemos que esto está considerado con una óptica de tiempos modernos: 1) no se trataba, como se ha visto, de una verdadera venta; 2) no podía concebirse en aquellos tiempos una cortapisa tal para el manejo que el *pater* debía hacer de los recursos familiares: el poner *in causa mancipi* a un hijo equivalía a que un padre actual, para ayudarse a subvenir a las necesidades de su familia, pusiera a trabajar a su hijo bajo órdenes de un patrón; 3) una emancipación no suponía, de por sí, una ventaja para el *filius*: si no recibía algo del *pater*, quedaría libre, pero sin un centavo, privado de la solidaridad familiar y sin derechos sucesorios *ab intestato*. Creemos que lo nuevo que se consignó en la ley fue el *modus operandi*: la realización de tres rituales o formales *mancipationes*— requerido para que tuviera lugar una emancipación o una adopción, instituciones que se hacían necesarias en una sociedad más individualista y de grupos familiares más reducidos.
- * La posterior ampliación de ese precepto, hecha por la jurisprudencia, en el sentido de que con una sola *mancipatio* se libera de la patria potestad a las mujeres o a los nietos, parecería confirmar nuestra opinión: se trata de mayores o menores requisitos para un fin determinado y no de sancionar abusos del *pater*.

I. El *pater* mancipa tres veces al *filius* a un adquirente fiduciario, quien, a continuación de la primera y segunda *mancipatio*, lo manumite, con lo que automáticamente vuelve a la patria potestad del *pater*. A la tercera *mancipatio*, el que era *filius*, de acuerdo con el precepto decenviral, queda libre del poder del *pater* pero *in causa mancipi* del adquirente fiduciario. Faltaba ahora que el adoptando cayera en la patria potestad del adoptante. Este lo reivindica como hijo propio en un juicio y el adquirente fiduciario no se opone: al no haber contradicción, el pretor adjudica al adoptando como *filius* al reivindicante. Así, por esta *in iure cessio*, el adoptante llegaba a tener bajo su patria potestad al adoptado en calidad de *filius* o de *nepos* (nieto).

II. No ha habido requisitos ni restricciones para la adopción: se trataba de algo privado entre dos *pater familias* a propósito de un *filius* cuya opinión y conveniencia no interesaba a la comunidad. Otra cosa era el problema que entrañaba una adrogación: la desaparición de una familia y un culto.

En el derecho justinianeo se distinguirá entre (A) *adoptio plena* y (B) *minus plena*, según sea hecha por (A) un ascendiente paterno o materno o (B) por cualquier otro *sui iuris*.

Solamente la primera produce los efectos de la adopción clásica: la *capitis deminutio minima* del adoptado. La segunda no sustrae al adoptando de la patria potestad de su *pater* originario y se limita a atribuirle una expectativa sucesoria sobre el patrimonio del adoptante. En cuanto a las formas, Justiniano dispone que la adopción se haga *imperio magistratus* (por imperio del magistrado), sin necesidad de las tres *mancipationes* y la ficticia reivindicación. Pero se plantean requisitos, como el consentimiento del adoptado y que el adoptante tenga por lo menos unos 18 años más que el adoptado.

CONVENTIO IN MANUM

Es el cambio de *status* por el cual, dadas ciertas condiciones, la mujer al casarse con un *pater familias* o un *filius familias* queda sujeta al poder jurídico llamado *manus* del *pater familias* y en condición de hija (*loco filiae*) o de nieta (*loco nepotis*), respectivamente.

Es pues una *capitis deminutio minima*, sea que la mujer fuere *sui iuris*, sea que estuviese bajo la patria potestad de su *pater* originario.

I. Las fuentes y los manuales hacen referencia a tres modos de producirse tal cambio de *status*: dos actos—*confarreatio* y *coemptio*— y una especie de prescripción adquisitiva—*usus*.

La *confarreatio* era una antigua ceremonia religiosa de los patricios con asistencia de 10 testigos y del *Flamen Dialis*. Su nombre deriva del *panis farreus* (pan de cebada), que comido en común habría simbolizado una perfecta comunión de vida y constituido, tal vez, el antecedente de las modernas tortas de boda.

La *coemptio* (compra) es un acto del *ius civile*, una *mancipatio* por la cual se opera la constitución del poder del *pater* sobre la mujer.

93

504: 1

92

El *usus*, como se ha visto, era el ejercicio fáctico de un derecho que por el transcurso del tiempo daba lugar a la titularidad jurídica de ese derecho: si la mujer durante un año había estado conviviendo con su marido, bajo su poder o el del *pater* de éste, se entendía, por aplicación analógica del precepto decenviral sobre la *usucapio*, que sobre ella se había adquirido la *manus*.

- En realidad, el desarrollo de esta institución debe, en nuestra opinión, de haber sido el siguiente. En los tiempos anteriores a la constitución de la *ciuitas*, la real convivencia de la mujer en el grupo del marido significaba, sin más, y, tal vez, desde el primer momento, la pertenencia a ese grupo. Sólo cuando se desarrolla una sociedad civil que hace perder vigencia a los grandes grupos parentales, relaja su hermetismo y da cuadro a un juego más individualista de las relaciones jurídicas y económicas, puede haberse tenido en cuenta el interés o conveniencia, para la mujer casada, en permanecer vinculada jurídicamente con su familia de origen.
- Para posibilitar tal nueva situación —antes incongruente— de estar en un grupo pero pertenecer a otro, la jurisprudencia pontifical debe de haber traído, por analogía con la interrupción de la *usucapio*, esa solución que se consagra en la ley de las XII tablas, el *trinoctium*: si la mujer pasa tres noches fuera del hogar conyugal, interrumpe la prescripción adquisitiva de la *manus* sobre ella que cumpliría el *pater* con un año de *usus* (ejercicio de poder) sobre ella.
- Al pasar los siglos se afirman las tendencias individualistas y una concepción de la familia con base en el parentesco de la sangre y no en el vínculo político de la sujeción a un mismo *pater*. Que la mujer quede *in manu* se hace cada vez más raro; lo común es que siga perteneciendo a su familia original y conservando sus derechos a suceder *ab intestato*. Ya habrá dejado de ser necesario marcar anualmente con la práctica del *trinoctium* la intención de permanecer vinculada con su familia.
- Se produce una inversión: lo que debe ser explicitado ahora es lo que antes se presumía, lo que era regla: el ingreso en la *manus* (*conventio in manum*) del *pater* de la familia del marido. La jurisprudencia debió entonces reconocer actos que dieran lugar a esa *conventio*. Esos fueron la vieja *confarreatio*, cada vez menos practicada en razón de que evocaba una apretada comunidad de vida y una época de completa integración de la mujer en el grupo de su marido, y la *mancipatio*, utilizada desde muy antaño para constituir poderes sobre cosas y personas.
- No habría habido, pues, tres modos de producirse la *conventio in manum*, sino un modo de evitarla —el *trinoctium*— cuando ella era la regla, y dos de constituir la —la *confarreatio* y la *coemptio*— cuando lo normal y corriente era el mantenimiento de los lazos de la mujer con su familia originaria.

II. Obsoleta la *manus*, la mujer no integrará más la familia del marido, pero se irá reconociendo al vínculo conyugal como productor de efectos jurídicos en el ámbito familiar del marido: la mujer adquirirá derechos sucesorios y alimentarios como cónyuge y no, como antes, por razón de vínculo agnaticio.

MODOS DE EGRESAR DE LA FAMILIA

En los tiempos precívicos hubiera sido imposible concebir una salida voluntaria de cualquier miembro fuera de los cuadros cerrados de los grupos parentales.

Después, en forma distinta a lo que ocurría contemporáneamente en otras comunidades indoeuropeas, los hijos no alcanzaron, por razón de edad o casamiento, a salir de una patria potestad que era atributo vitalicio del *pater*.

La exclusión de la familia era sólo posible por el poder de disposición del *pater*: él podía efectuar una *noxae deditio* del *filius*, entregarlo *in causa mancipi*, darlo en adopción, y hacer la *conventio in manum* de una hija, etcétera.

Un modo especial de salida de la familia ocurría cuando tenía lugar un divorcio en un matrimonio que se había acompañado con la *conventio in manum*. Para que la mujer no quedara en el grupo familiar del marido, se procedía a un acto jurídico opuesto al que había originado la *conventio*: una *diffarreatio*, si había tenido lugar una *confarreatio*, o una *remancipatio*, si la mujer había ingresado en virtud de una *coemptio*.

EMANCIPACION

Cuando se producen las transformaciones sociales a que veníamos aludiendo, surge entonces la emancipación como acto hábil para que el *pater* libere de su patria potestad a un *filius familias* y lo convierta así en *sui iuris*.

I. El procedimiento es el mismo que se ha visto usado para la adopción, sólo que luego de la tercera *mancipatio* —por la cual el *filius* ha salido definitivamente de la patria potestad del

pater—, el adquirente fiduciario procede a remanciparlo al *pater*, quien al manumitirlo conservará sobre él el derecho de patronato.

II. Esta compleja formalidad terminará en la época justiniana, como la adopción, suplida por una presentación ante magistrado competente.

III. Como acto absolutamente libre y propio del *pater*, la emancipación no está sujeta a límites ni requisitos; y no es necesario que el *filius* dé su consentimiento.

- Sin embargo, en la época posclásica ese consentimiento se exigirá como en el caso de la adopción.
- A veces, el *pater* está constreñido a emancipar un *filius*: por ejemplo, según Trajano, en la hipótesis de malos tratos.
- En el derecho justiniano hay emancipación ordenada por la ley en el caso de que el *filius* haya accedido a ciertos cargos civiles o eclesiásticos o que el *pater* haya usado del *ius exponendi* o prostituido a la hija.

IV. La emancipación produce una *capitis deminutio minima*: todo vínculo y derecho respecto de la familia queda roto. Esto se atenuará con la mayor relevancia que se irá dando a la cognación, que, como parentesco natural, no sufre alteración por la emancipación.

Si el emancipado tiene un peculio profecticio, lo conserva si explícitamente no se lo quita el *pater*. Conserva el castrense o cuasi castrense y cesa para el *pater* el usufructo del adventicio, aunque Constantino estableció que, en compensación, el *pater* quedara con el tercio de ese peculio. Justiniano limitó esa compensación al usufructo de una mitad.

CAPACIDAD PATRIMONIAL DE LOS FILIIFAMILIAS

Ya se ha visto que sólo a los *patres familias* o *sui iuris* les es reconocida la plena capacidad jurídica. A los *alieni iuris*—sujetos a la patria potestad, *manus* o *mancipium* de otra persona— no se los reconoce como titulares de derechos reales—*filius nihil suum habere potest* (el hijo no puede poseer nada suyo)—ni de crédito. Se ha visto, sin embargo, que, siendo incapaces

de derecho, pueden—al igual que los esclavos y si no tienen impedimentos de edad o salud mental— ser capaces de hecho o de actuación. Pueden cumplir actos de adquisición, pero éstos aprovechan, sin necesidad de su previo consentimiento, al *paterfamilias*, que, sin embargo, no queda obligado por las deudas de los a él sujetos.

Ese principio absolutamente excluyente de capacidad patrimonial de los *filiifamilias* subsistió siempre, teórica y formalmente, pero el desarrollo gradual de los peculios lo fue deteriorando en la realidad.

En el derecho justiniano ha desaparecido prácticamente, aunque subsiste para el *filius* la incapacidad de nombrarse herederos.

PECULIUM PROPECTICIUM

Llamado así por ser un peculio *a patre profectum* (proveniente del *pater*). Se trataba de una parte del patrimonio del *pater* que éste concedía al *filius*—o a un esclavo— para que se lo administrara y/o gozara. La propiedad seguía siendo del *pater*. La jurisprudencia y el pretor admitieron que el *pater* fuera civilmente responsable por las deudas contraídas por los sujetos a su potestad dentro del monto del peculio—*actio de peculio*.

PECULIUM CASTRENSE

Para los *filiifamilias*—no ya para los esclavos—, esa práctica de manejar una parte desglosada del patrimonio tuvo un mayor desarrollo. A partir de Augusto, el llamado peculio castrense fue comprendiendo lo adquirido por el *filius* durante y con motivo de su carrera militar, y aun ciertas donaciones y herencias. Sobre él el *filius* se comporta como un *pater*: si manumite, él resulta patrono y no su *pater*; puede donar *mortis causa* y testar; hasta puede contraer obligaciones con su *pater*.

- Si moría intestado, entonces el peculio castrense iba a su *pater*, no *iure hereditatis* (en condición de herencia), sino *iure peculii* (en condición de peculio); es decir, haciéndolo responsable por deudas sólo hasta el monto del peculio.

* De todos modos, Justiniano dispuso que en vez de ir al *pater*, el *peculio castrense* fuera objeto de sucesión *ab intestato*. Es decir, borró lo único que vinculaba el *peculio castrense* con el patrimonio del *pater*.

PECULIUM QUASI CASTRENSE

A partir de Constantino, la legislación consolida más ampliamente la independencia patrimonial del *filiusfamilias*, asimilando al *peculio castrense* todos los bienes adquiridos en la función pública o por larguezas imperiales.

PECULIUM ADVENTICIUM O BONA ADVENTICIA

Pero el mismo Constantino había abierto el camino a que se reservara al *filius* lo recibido por línea materna, sea donaciones, legados o herencias. El *pater familias* no adquiría, como antes, esos bienes, sino que sólo tenía el usufructo de ellos.

Justiniano dispuso finalmente que el *pater* sólo sería propietario de lo que el *filius* adquiriera *ex re patris* (a partir del patrimonio del *pater*), es decir, con recursos paternos. Todo lo otro adquirido sería *peculium adventicium* (peculio que viene de otra parte). De él formalmente, el *pater* era el titular, pero no tenía su disposición, sino sólo la administración y el usufructo. Y ni siquiera éstos, cuando se trataba (A) de un legado o donación bajo condición de que el *pater* fuera excluido o (B) de una herencia adquirida contra la voluntad del *pater* o (C) del llamamiento conjunto en la segunda clase de herederos *ab intestato* según las novelas 118 y 127.

Por lo tanto, en el derecho justiniano, sólo el propecticio continuó siendo verdadero peculio.

ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS

Lo que significan los peculios como excepciones a la exclusiva capacidad patrimonial del *pater*, significan las *actiones adiecticiae qualitatis* (acciones de índole adicional) como excepciones en el principio del viejo *ius civile* de que el *pater* no queda obligado por las deudas contraídas por los sujetos a su potestad.

Por razones de equidad y de fomento del tráfico comercial, el pretor otorga ciertas acciones contra el *pater*, que se añaden a las directas que competen al acreedor contra los que personalmente contrajeron las deudas.

I. La acción *de peculio et de in rem verso* es de una sola fórmula, pero con dos *condemnationes*: una estableciendo la responsabilidad del *pater* por el monto de la utilidad o enriquecimiento por él obtenido del crédito; la otra, por hasta el monto del peculio, cuya existencia fue el presupuesto del crédito. Se le indica al *iudex* condenar por la primera y, si no hay enriquecimiento o es menor que la deuda, condenar en los límites del peculio.

II. La acción *quod iussu* (por cuanto con orden) corresponde por el total de la deuda cuando ésta ha sido contraída con orden o ratificación del *pater*.

III. La acción *exercitoria* se da contra el *pater* armador por la totalidad de las deudas contraídas por el *magister navis* (capitán de la nave), sea éste un sometido a la potestad de aquél o un *sui iuris*.

IV. La acción *institoria* es similar a la anterior, sólo que referida a las deudas contraídas por el gerente (*institor*) de establecimiento comercial.

V. La acción *tributoria* se da contra el *pater* en el supuesto de que el sujeto a la potestad de aquél, en el ejercicio de un comercio en el que se hubiere empleado el peculio, resultare insolvente y terceros acreedores, en concurso con el *pater*, se consideraran perjudicados por no haber recibido, por dolo del *pater* en las operaciones distributivas, lo que les correspondía.

EL MATRIMONIO

La concepción romana del matrimonio es muy distinta de la que existe hoy en los pueblos de cultura occidental, debida ésta, sobre todo, a la influencia del derecho canónico, es decir, del cristianismo.

Ni los juristas romanos lo intentaron, ni podríamos hacerlo nosotros, definir o encuadrar en alguna categoría jurídica la institución matrimonial romana.

I. Por cierto, se trata de una institución social con relevancia jurídica que consiste en una permanente situación, en un *status*, de convivencia de dos personas de sexo distinto con la voluntad de ser marido y mujer (*affectio maritalis*) y constituyentes de una sociedad doméstica.

- Se la ha comparado con la institución de la posesión: en ambos casos se requiere un elemento material —efectivo señorío y convivencia, respectivamente— y otro anímico —*animus domini* y *affectio maritalis*—; en ambos casos no juega la institución del *post liminium*, pues se trata de relaciones que tienen relevancia jurídica en tanto subsiste la efectiva situación fáctica que constituye su elemento material.

II. Claro que el elemento anímico predomina sobre el material: *nuptias non concubitus sed consensus facit* (al matrimonio lo hace el consentimiento y no la unión carnal).

Ese elemento anímico, la voluntad, no se requiere —como en el derecho moderno— en forma de expresión solemne en un instantáneo acto inicial del que se originan las consecuencias jurídicas permanentes del estado matrimonial, las que subsisten aunque esa voluntad haya dejado de existir.

Para los romanos se requiere una voluntad permanente, continua, que se manifiesta o presume con el hecho mismo de la convivencia.

El matrimonio romano dura exactamente lo que dura esa *affectio maritalis*. Cuando falta, se disuelve el matrimonio: hay divorcio, que no es un acto o negocio jurídico —como no lo es tampoco el matrimonio—, sino el dejar de ser matrimonio por haber desaparecido la voluntad de convivir en sociedad doméstica.

- No hay, pues, formalidades ni un acto jurídico iniciador del matrimonio: ni la ceremonia religiosa de la *confarreatio* ni la social de la *domum deductio* (introducción en la casa [del flamante marido]) de la novia son condición del *status* matrimonial, aunque sirvan como pauta para saber cuando se ha iniciado ese *status*.
- Pero Justiniano exigirá como prueba del matrimonio de personas de alto rango —*illustres*— la confección de un instrumento escrito dotal,

y, por influencia de la concepción cristiana del matrimonio como sacramento, se tenderá a considerar prueba de la *affectio maritalis* la bendición sacerdotal.

- Tampoco se necesita un acto jurídico ni menos una intervención judicial para que se disuelva ese estado matrimonial.
- Tal es la inexistencia de formas específicas en que debe manifestarse la voluntad de los cónyuges, que en Derecho Romano se llega a considerar que la unión entre un hombre y una mujer libres y con *conubium* entre sí debe presumirse matrimonio.

III. La configuración jurídica del matrimonio resulta transformada, en el período posclásico, sobre todo por la influencia del cristianismo. Los textos del siglo V y VI le dan al *consensus* y a la *affectio maritalis* el significado de una existencia de una voluntad inicial de los contrayentes a la que se le da fuerza constitutiva del estado matrimonial, que subsistirá independientemente del elemento material —efectiva convivencia— y del voluntario —*affectio maritalis*— que se han mencionado como constituyentes del matrimonio clásico.

Esta mutación no se explicita teóricamente, pero se deduce de algunos elementos institucionales: se configura el delito de bigamia, se habla de un precedente matrimonio con o impedimento para contraer otro. En la concepción clásica ser a esto imposible: el matrimonio primero deja automáticamente de existir cuando tiene lugar el cese de la *affectio maritalis*, cese que se presumiría sin más ante la concertación de un segundo matrimonio.

Los juristas clásicos entienden, pues, que existe el estado social de matrimonio, con las conexas consecuencias jurídicas, cuando un hombre y una mujer libres que tienen *conubium* entre ellos —es decir, capacidad reconocida por el *ius civile* de constituir entre ellos una relación de *iustae nuptiae*— y que no tienen impedimentos legales, establecen una relación de convivencia con la efectiva intención y continua voluntad de permanecer unidos como marido y mujer.

IV. La famosa definición de Modestino: "*Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*" ("El matrimonio es la unión del varón y la mujer, sociedad de toda la vida, comunión del ordenamiento divino y humano"), más que técnicamente jurídica, alude a la base real de la unión de dos personas de diverso sexo con voluntad de total comunión de vida social y espiritual.

Lo de *consortium omnis vitae* —si no es una interpolación justiniana— debe interpretarse, no como indicando un carácter vitalicio o indisoluble del matrimonio, sino como intención o voluntad de los cónyuges, que debe ser la de constituir una comunión perpetua y no un vínculo temporal.

La voluntad debe, pues, ser plena e incondicionada.

REQUISITOS

Se requieren tres aspectos positivos: idoneidad física —pubertad—, capacidad jurídica —*conubium*— y consentimiento.

IDONEIDAD FISICA

Los contrayentes debían ser púberes. Para Justiniano, quedó firme que el hombre alcanzara la pubertad a los 14 años y la mujer a los 12.

CONUBIUM

Este requisito esencial no tiene parangón en el derecho moderno por haberse originado en una concepción jurídica de la personalidad humana distinta de la actual, basada en la igualdad de todos los hombres.

En el mundo antiguo, el exclusivismo en el uso de las instituciones, que lleva al principio de la personalidad* de las leyes, y las diferencias no sólo entre libres y esclavos, sino también entre las categorías de ciudadanos, explican el no reconocimiento de capacidad para constituir un matrimonio válido a personas de distintos *status* sociales o grupos nacionales.

Así, para que existiera matrimonio válido con todos los efectos a él inherentes, era preciso que los contrayentes tuvieran recíprocamente, uno respecto del otro, esa capacidad llamada *conubium*. Los plebeyos no lo tuvieron con los patricios hasta la *lex Canuleia* en el 445 a.C., ni los ciudadanos con el resto de los hombres libres del Imperio —los peregrinos— hasta el edicto de Caracalla en el año 212 d.C.

- * En el tecnicismo jurídico romano se acostumbrará hablar de falta de *conubium* para indicar ciertas situaciones o circunstancias que impiden el matrimonio, en lugar de configurarlas, como se hace hoy en día, como impedimentos relativos o absolutos.

CONSENTIMIENTO

Aparte del de los contrayentes, para que exista el matrimonio se requiere el del *paterfamilias* del cónyuge *alieni iuris*. Este consentimiento, que tiene el carácter de una *auctoritas**, se habría requerido —según el derecho clásico— sólo para el momento inicial del matrimonio; no como el de los cónyuges, que debe ser permanente. Así, pues, una vez dado el consentimiento del *pater*, su cambio de voluntad no puede alterar el hecho jurídico del matrimonio, cuya persistencia depende exclusivamente de la *affectio maritalis*.

- * También el padre del varón contrayente, si no es *pater* todavía, debe expresar su consentimiento.
- * Con el propósito de favorecer la realización de matrimonios, la *lex Iulia* permitió recurrir al magistrado en caso de negativa inmotivada del *paterfamilias*.

IMPEDIMENTOS

Se trata de circunstancias que, formuladas negativamente, se designan con ese término del derecho canónico.

Derivan de motivos éticos, sociales y religiosos. Son absolutos si la incapacidad de contraer matrimonio es en relación con cualquier persona, y son relativos si esa incapacidad es respecto de personas determinadas.

Por precedente matrimonio. — El matrimonio romano fue siempre monogámico, y la bigamia, causal de infamia.

Por diferencias sociales. — No parece haber estado prohibido en el antiguo *ius civile* el matrimonio entre ingenuos y libertos, pero la *lex Iulia* prohibió a la clase senatorial el matrimonio con libertas o con mujeres "abyectas": actrices, prostitutas, etcétera. En el siglo VI d.C. se prohíbe el matrimonio de una mujer libre con un colono de otro.

Por sanciones penales. — Fue prohibido por la *lex Iulia* el matrimonio de la adúltera. Posteriormente, el del raptor con su víctima.

Por motivos éticos. — Está prohibido el matrimonio del tutor, su *pater* y sus descendientes con la pupila, antes del rendimiento de cuentas. También el de los magistrados con mujeres de su provincia, hasta no haber abandonado sus funciones en ella.

Por motivos religiosos. — Por influencia del cristianismo se prohibió el matrimonio entre hebreos y cristianos y entre pagano y ahijada.

Por motivo de parentesco. — En línea recta, entre ascendientes y descendientes, está prohibido en cualquier grado. En línea colateral, entre hermano y hermana y entre tíos y sobrinos. Claudio, para poder casarse con la hija de su hermano Germánico, consiguió un senadoconsulto que permitió el matrimonio entre tío y sobrina, pero manteniendo la prohibición de casarse con una hija de una hermana.

Los mismos impedimentos corren para la parentela adoptiva, a no ser que cese por emancipación de alguno de los futuros contrayentes. También para la *cognatio* de los esclavos, si han sido liberados.

Por afinidad* estaban prohibidos los matrimonios entre suegro y nuera, suegra y yerno, padrastro e hijastra, madrastra e hijastro. La influencia cristiana extendió esta prohibición a la línea colateral.

Plazo para contraer nuevo matrimonio. — No puede contraer matrimonio la mujer antes de transcurridos diez meses desde la muerte de su anterior marido. Ampliado ese período a un año, se extendió también a los casos de divorcio: su objeto era evitar la confusión —*turbatio sanguinis*— en cuanto a la pa-

ternidad de eventuales hijos concebidos. Por eso cesaba inmediatamente después de un parto. No se trata aquí de un impedimento: si se viola esa disposición, el matrimonio resultante es válido, pero contrayentes y *patres* consentidores quedan sujetos a sanciones, entre ellas la infamia.

EFFECTOS

Una unión conyugal con los requisitos y sin los impedimentos anotados, y siendo el varón ciudadano romano, produce los efectos propios del matrimonio romano (*iustae nuptiae*).

(A) Los concebidos en tal unión son hijos legítimos, ciudadanos romanos —cualquiera sea el *status civitatis* de la mujer, siempre que existiera *conubium* entre ella y el ciudadano romano—, y sujetos a la patria potestad del *pater*, sea el mismo progenitor o un ascendiente de éste.

(B) Se establece el vínculo de afinidad, relación entre un cónyuge y los cognados del otro.

(C) Hay obligación de fidelidad por parte de la mujer.

* Al principio la reacción del *pater* ante el quebrantamiento era plenamente admitida.

* También cuando la *lex Iulia de adulteriis* (17 a.C.) configuró delito al adulterio de la mujer, dejó a salvo, en ciertas circunstancias, aquella reacción.

* A pesar de la influencia cristiana, no se llegó a la consagración legal de la reciprocidad de ese deber conyugal.

(D) Entre cónyuges se admite el *beneficium competentiae**. En el derecho posclásico, en razón de la *reverentia* entre cónyuges —deber que resulta así jurídico—, se prohíben entre ellos las acciones que acarrearán infamia.

(E) Entre cónyuges se establecen derechos a alimentos y sucesorios.

(F) Juega la *praesumptio Muciana**.

(G) Existe prohibición de donaciones entre cónyuges, mientras transcurra el matrimonio.

* Como se ha visto, además del caso en que al matrimonio lo haya acompañado la *conventio in manum* y, por tanto, la mujer esté jurídicamente sujeta al *pater*, los cónyuges no se hallan en plano de igualdad, sino

96

504 1

95

que la mujer queda subordinada al marido: ella sigue la condición y el domicilio de éste; se castiga el adulterio de la mujer, no el del marido; el marido tiene el interdicto *de uxore exhibenda et ducenda*, para reclamar le sea entregada la mujer, etcétera.

MATRIMONIO PEREGRINO

La unión matrimonial entre peregrinos o entre un peregrino y una ciudadana romana, dotados recíprocamente de *conubium*, no producía esos particulares efectos y consecuencias de las *iustae nuptiae*. Los hijos resultantes tienen el *status civitatis* del padre en el momento de engendrarlos y están regidos por las normas vigentes en el ordenamiento jurídico de la comunidad peregrina del padre.

CONCUBINATO

Con este nombre se designa una unión estable de un hombre y una mujer sin intención o sin posibilidad de ser marido y mujer.

Sin intención, por la falta de *affectio maritalis* y del *honor matrimonii* (trato matrimonial); sin posibilidad, por la falta de *conubium*.

I. En el período republicano, el concubinato fue una relación de hecho no prohibida ni reconocida por la ley, ni reprobada por la opinión pública.

II. Adquirió mayor desarrollo a continuación de las leyes *Iulia de adulteriis* y *Iulia et Papia Pappaea*.

(A) La primera penaba como *adulterium* —cuando alguno de la pareja era casado— o *stuprum* —cuando ambos eran solteros— a toda relación sexual extramatrimonial y enumeraba a mujeres con las que no se consideraba configurable el *stuprum* (*in quas stuprum non committitur*): esclavas, mujeres del espectáculo público, condenadas como adúlteras, prostitutas, nacidas de humilde origen y libertas. Era posible, en este caso, una relación extraconyugal estable y no punible.

(B) La segunda negaba *conubium* entre esas mujeres y los ciudadanos ingenuos o, por lo menos, los senadores y su descendientes.

La una, pues, eximía de pena las relaciones con esas mujeres; la otra les quitaba posibilidades de *iustae nuptiae*: ambas incitaban o favorecían el concubinato. El exceso moralizante y jerarquizante producía, pues, resultados contrarios.

- En la época clásica, pues, como el concubinato con esas mujeres no era matrimonio ni unión ilícita, podía para el hombre coexistir con su matrimonio. Una mujer casada, en cambio, hubiera configurado el delito de adulterio si constituía, además, un concubinato con un tercero.
- Obsérvase, por lo demás, que teóricamente no era posible, a partir de esa legislación, el concubinato con mujer honesta e ingenua: o era cónyuge o era cómplice de un *stuprum* o *adulterium*.
- Sin embargo, concubinatos con mujeres honestas e ingenuas existieron de hecho, sin ser castigados, a pesar de que la *lex Iulia* los consideraba delito.

III. El concubinato adquirió relevancia jurídica por influencia del cristianismo: se le atribuyeron efectos jurídicos y se establecieron requisitos, configurándolo como una unión similar, aunque inferior, al matrimonio: se le impuso la monogamia —es decir, que no se podía tener esposa y concubina, ni dos concubinas—: se requirió pubertad y falta de impedimentos por parentela y afinidad.

Al suprimir los impedimentos matrimoniales basados en razones sociales, el cristianismo quitó la principal causa de los concubinatos y con la legitimación * favoreció la conversión de éstos en matrimonio.

- Justiniano, eliminada toda diferencia de condición social entre mujeres que sólo podían ser esposas y las que podían ser concubinas, estableció la obligación de hacer una previa declaración formal para que la unión con mujer ingenua y de vida honesta fuera considerada concubinato y no presumida matrimonio. De no cumplir ese requisito, y ser negada la existencia del *affectio maritalis*, esa unión sería castigada como *adulterium*.

SPONSALIA

Es la promesa recíproca de futuro matrimonio. Institución similar a la de nuestro compromiso, pero con mayores formalidades y relevancias jurídicas, que, por cierto, varían según las épocas.

Debe especialmente destacarse que por influencia del cristianismo se equiparó, en algunos efectos jurídicos, la condición de *sponsi* (comprometidos) con la de los cónyuges.

I. Hasta fines del período republicano, aquel compromiso, contraído por *sponsio* o *stipulatio* entre los *patres* de los futuros contrayentes, habría dado lugar a reclamación judicial *ex sponsu* (por lo prometido) por un monto pecunario según el interés (*quantum interfuerat*) del actor en que la mujer fuera dada o recibida —según los casos— en matrimonio.

II. La jurisprudencia clásica, en cambio, juzgó *contra bonos mores* (contra las buenas costumbres) cualquier estipulación que constriñera la libertad de casarse o de divorciarse. Los esponsales no tuvieron entonces eficacia jurídica de dar acción para el cumplimiento, aunque permitió a los célibes comprometidos con mujeres menores de 12 años eximirse de las penas de las leyes *Iulia* y *Papia Poppaea*. Se consideró pasibles de infamia a quienes se establecieran en esponsales con más de una persona. Los esponsales, pues, tuvieron, fundamentalmente, un valor moral y social, como en los tiempos modernos.

III. A partir del siglo IV y por influencia del cristianismo; las constituciones imperiales establecen un régimen de formas y de consecuencias de los esponsales.

El *sponsus* o la *sponsa* pueden reclamar la devolución de sus donaciones hechas en vista al futuro matrimonio sólo cuando éste no se realizare por culpa de ellos.

Fueron efectos de la relación —asimilada en cierto sentido a la matrimonial— entre *sponsi*, entre otros, los siguientes: la relación sexual de la *sponsa* con un tercero, se considera adulterio; la muerte del otro o de sus padres es considerada parricidio; se establecen impedimentos iguales a los de la afi-

nidad*; otros impedimentos del matrimonio juegan también para los esponsales.

IV. Subsistirá, no obstante, la plena libertad de contraer vínculos matrimoniales y la consiguiente nulidad de cualquier cláusula penal en su contra, aunque esto último haya sido en cierto sentido superado por la difusión de la práctica de las *arras**.

DISOLUCION DEL MATRIMONIO

Obviamente, por muerte de uno de los cónyuges. Pero existen muchas más causales de disolución en el Derecho Romano que en los modernos: como se concibe el matrimonio como un *status* permanentemente efectivo y querido —y no como resultado de un instantáneo acto jurídico inicial—, las capacidades y requisitos deben existir no sólo al principio, sino continuadamente a lo largo de toda la duración del matrimonio, duración que queda, así, condicionada: (A) a la no aparición de incapacidades o impedimentos; (B) al mantenimiento de los requisitos; (C) a la subsistencia del elemento material de convivencia y (D) del voluntario, la *affectio maritalis*.

El cristianismo, de acuerdo con el precepto evangélico de la indisolubilidad del matrimonio, descartará algunos de estos motivos de disolución al orientarse hacia la concepción canónica del matrimonio como subsistente para siempre, luego de un consentimiento inicial.

(A) Se disuelve el matrimonio si un cónyuge deviene esclavo, o pierde —por una *aqua et igni interdictio* o deportación— su *status civitatis*, o el casado con una liberta llega al Senado, o le sobreviene por adopción un parentesco que cause impedimento.

* Justiniano hace que perdure el matrimonio con la liberta y con el cónyuge deportado y obliga a emancipar para evitar parentesco adoptivo que cause impedimento.

(B) Se disolvía, en los primeros tiempos, el matrimonio cuando la voluntad de los *patres*, que habían consentido, cambiaba.

97

504 1

%

* Pero Antonino Pío prohibió que el *pater* pudiera separar un *bene concordans matrimonium*. En las sentencias de Paulo se afirma que la voluntad del *pater* es necesaria para que tenga lugar el matrimonio, pero no suficiente para disolverlo.

(C) Se disuelve con la captura del cónyuge por el enemigo, pues, como se ha visto, no se aplicaba el *ius postliminii* *.

* En cambio, en el derecho justiniano no se le permite al cónyuge contraer nuevo matrimonio si no han transcurrido cinco años de cautiverio y sin noticias de la supervivencia del otro cónyuge.

(D) Cuando falta la *affectio maritalis*, hay disolución por divorcio. Ya se ha visto que el matrimonio es una situación fundada sobre una permanente *affectio maritalis*: al cesar ésta, cesa aquél.

El divorcio, pues, no es un acto jurídico ni sujeto en principio a formas.

Se ha visto también que si hubo *conventio in manum*, entonces si se necesitarán actos solemnes para deshacerla: la *diffarreatio* * y la *remancipatio* *, según los casos.

EL DIVORCIO EN EL DERECHO POSCLASICO

Desde Constantino, y por influencia del cristianismo, se inicia una lucha contra el divorcio: se establecen penas y desventajas patrimoniales para desalentarlo, pero no se llega nunca a negar validez al divorcio, tan consustanciado estaba con la concepción romana del matrimonio.

En el derecho justiniano se establece un régimen basado en cuatro hipótesis:

(A) *Divortium ex iusta causa*. Resulta de la voluntad unilateral de un contrayente y está motivado por culpa del otro: adulterio e inconducta de la mujer, atentado contra la vida, incitación a la prostitución, conspiración contra el emperador, etcétera. El repudiado pierde la dote o la *donatio propter nuptias*, y si se trata de una adúltera, es encerrada en un convento.

(B) *Divortium sine causa*. También unilateral, pero sin las causas de culpabilidad del otro cónyuge. Es desalentado con

la imposición de varias cargas y sanciones, pero se lo reconoce válido.

(C) *Divortium ex communi consensu* (por común consenso). Llegó a ser prohibido por Justiniano, pero restablecido inmediatamente después de su muerte (565 d.C.) por su sucesor Justino II.

(D) *Divortium bona gratia*. Debido a causa que no produce sanción ni para el que la experimenta ni para el que pide el divorcio: incapacidad de generar; cautiverio bélico de más de cinco años; ausencia del soldado sin dar noticias por más de cuatro años; caída en esclavitud de un liberto; locura furiosa; voto de castidad o reclusión en convento, etcétera.

REGIMEN MATRIMONIAL DE BIENES

El régimen de bienes del matrimonio variará según se trate de un matrimonio realizado con una *conventio in manum*, o no, es decir, un matrimonio *sine manu* o libre.

REGIMEN DE BIENES ESTANDO LA UXOR IN MANU

La regla general será que se produce una absorción por parte del marido de los bienes que tenga la mujer; y si aquél está sometido a la *patria potestas* de otro, por parte de este último. De tal modo que no existe sino un solo patrimonio.

Debemos, sin embargo, distinguir:

(A) Si la *uxor in manu* había sido *filia* —y por ende *alieni iuris*—, su situación no variará, puesto que si bajo su *pater* no tenía capacidad patrimonial, tampoco la podía tener ahora; lo único que ocurre es que ha cambiado la titularidad del poder, que ahora reside en su marido, y si éste es *alieni iuris*, en el *pater* del que dependiere.

(B) Si la *uxor in manu* había sido *sui iuris*, pierde su capacidad patrimonial y su patrimonio y todo lo que adquiriese

f9

después será para el marido. Y siendo éste *alieni iuris*, para el *pater* de quien dependiere.

- En este caso, al igual que en el caso del adrogado, sucede que los bienes de la mujer *sui iuris* pasan al patrimonio del marido, pero las deudas cesan —por *capitis deminutio*— para el *ius civile*.
- El pretor, para proteger a los acreedores de la mujer, les concederá, como a los de los adrogados, una *in integrum restitutio*°.

REGIMEN DE BIENES SIN ESTAR LA UXOR IN MANU

Acá la regla genérica es que cada uno de los cónyuges continúa manteniendo la situación patrimonial de que gozaba con anterioridad al matrimonio. Sin embargo, por la esencia comunitaria del matrimonio, el hombre mantendrá a su mujer en lo que ésta necesitare y, por otro lado, resultará usual que la mujer confíe a su marido la administración de su patrimonio. Estos bienes, propios de la mujer y confiados al marido, son denominados *bona extra dotem* o también *parafernales*.

- Esta expresión griega —*parapherna*— es empleada en el derecho posclásico, y sobre todo en el justiniano, en el sentido indicado. En el derecho clásico —ya desde el siglo I— servía para designar, de acuerdo con una costumbre helenística, los bienes de la mujer que ésta agregaba a la dote, consistiendo por lo general en prendas personales, ajuar, etcétera. Esta "dote accesoria" corresponde en propiedad a la mujer, y si bien es administrada por el marido, éste debe restituirla una vez disuelto el matrimonio.

I. Respecto de estos bienes parafernales, se considera que el marido administrador está sometido a las reglas generales del mandato, debiendo, en principio, seguir las instrucciones dadas por la mujer propietaria. Respecto de los créditos parafernales, el marido se encuentra habilitado para su cobro, pudiendo ejercitar las pertinentes acciones.

II. En caso de duda acerca del origen de los bienes, rige acá una presunción, atribuida a Q. Mucio Scaevola (*praesumptio Muciana*), según la cual las adquisiciones hechas por la mujer casada —salvo prueba en contrario— se entendían que habían sido hechas por el marido, lo que significa que los bienes parafernales no se presumen.

REGIMEN DE LOS BIENES DOTALES

Se entiende en general por dote (*dos*) una cantidad determinada de bienes que la mujer, o un tercero, entregan al marido para cooperar en el mantenimiento de las cargas del matrimonio. (*onera matrimonii*).

- El propósito de la dote —aparte de la contribución a las cargas matrimoniales— parece también haber sido una función protectora de la mujer, una vez disuelto el matrimonio, de tal modo que se pudiera encontrar con bienes para enfrentar la vida posterior.
- Por lo general, la dote es constituida por el *pater* de la mujer —*dos profecticia*—, pero puede serlo también por la propia mujer o por un tercero. En ambos casos se llama *dos adventicia*. Se denominará *dos recepticia* si el tercero constituyente se ha reservado el derecho de pedir la restitución en caso de disolución del matrimonio.
- La constitución de la dote se realiza, ya mediante la entrega directa de los bienes que la constituyan —*dotis datio*, que se realiza por medio de una *mancipatio*, *in iure cessio* o *traditio*—; ya prometiéndola, por medio de la *promissio dotis*°; ya por un negocio más específico, la *dotis dictio*°.

Posteriormente, en la época posclásica, la dación efectiva de la dote se operará por la mera *traditio*. En cuanto a las promesas, Justiniano suprimirá la *dotis dictio*, y si bien quedará la *promissio dotis* como pacto legítimo°, al lado de ésta se acostumbrará a redactar un documento escrito —*instrumenta dotalia*—, que en el comienzo tuvo un valor probatorio, pero luego aparecerá como figura independiente.

I. La dote, en principio, pasa en propiedad al marido, pero en esto hubo una lenta evolución.

(A) En los primeros tiempos, el marido —o su *pater*— podía disponer libremente de los bienes dotal, porque se entendía que el objetivo de su establecimiento eran las cargas del matrimonio.

(B) En una segunda etapa, se comenzará a poner de relieve que si bien están en poder del marido, son, en realidad, de la mujer, destacándose el papel que podrían tener estos bienes en caso de disolución del matrimonio. Fue así que una *lex Iulia de fundo dotali* estableció la prohibición, para el marido, de enajenar los inmuebles *italicos* dados en dote, sin el consentimiento de la mujer.

98

504 11

92

- * Esta *lex Iulia de fundo dotali* era un capítulo de la *lex Iulia de adulteriis* —de la época de Augusto, año 18 a.C.—. Esta prohibición, al parecer, no abarcaba la nulidad sino en forma relativa, puesto que la única que la podía pedir era la mujer.
- * Esta prohibición fue asimilada, también, para la gravación de dichos inmuebles con el *pignus*, extendiéndosela en la época posclásica a los demás fundos, es decir, los provinciales.

(C) En la época justiniana, si bien formalmente se podría seguir hablando de propiedad del marido sobre la dote, en realidad, lo que éste detenta es un usufructo; incluso, muerta la mujer, la propiedad de los bienes dotalés va a los hijos; si bien el padre tendrá un usufructo cualificado.

II. Ya en la época republicana la mujer tendrá una *actio rei uxoriae* para reclamar la dote, una vez disuelto el matrimonio. Por ella se le indica al *iudex* que la restitución de los bienes dotalés se efectúe conforme al *aequum et bonum*.

- * Aparte de esta *actio rei uxoriae* se podía reclamar la restitución de la dote por medio de la *actio ex stipulatu* cuando hubiere mediado una *stipulatio* restitutoria de la dote por parte del marido. Por medio de esta *actio ex stipulatu* sólo se podía reclamar lo estrictamente convenido en esa *stipulatio*.

Restitución de la dote. — Estaba estructurada del siguiente modo.

(A) Si el matrimonio concluía por la muerte de la mujer, la regla general era que el marido retuviese la dote.

- * Pero si la dote era *recepticia*, el constituyente podía reclamar la devolución de los bienes. Del mismo modo, si era *profecticia*, el *pater* tenía derecho a ejercitar la *actio rei uxoriae*, siempre que hubiera sobrevivido a la mujer; de haber muerto antes, la dote quedaba consolidada para el marido.

(B) Si el matrimonio concluía por la muerte del marido o por divorcio, la mujer tenía la *actio rei uxoriae*. Si era *sui iuris*, la *actio* la podía ejercer sólo ella; si era *alieni iuris*, entonces su *pater*, con consentimiento de ella.

- * Los herederos de la mujer —o los del *pater*— tendrán derecho a pedir la restitución de los bienes siempre y cuando la mujer divorciada muriese y el marido estuviese en mora.

(C) El marido cuenta, para la restitución de la dote, con algunos beneficios:

1) Si se trata de bienes fungibles, podrá devolverlos en tres cuotas anuales (*annua, bima, trima die*); de ser otra clase de bienes, la devolución deberá ser inmediata.

2) Pero cuenta además con el *beneficium competentiae**, de tal modo que no puede ser condenado más allá de su activo patrimonial.

3) Podrá hacer uso de determinadas retenciones (*retentiones*), que importarán deducciones de lo que debe restituir:

a) *Retentio propter liberos* (por causa de hijos). Para el supuesto de disolución por muerte de la mujer, podrá —en caso de tener que devolver la dote— retener un quinto por cada hijo; si hubo divorcio por culpa de la mujer, podrá retener un sexto por cada hijo, no pudiendo pasar, en total, de tres sextos.

b) *Retentio propter mores* (por causa de costumbres). Para el supuesto de adulterio de la mujer, podrá retener un sexto; si se tratara de otras causas por culpa de la mujer —inmoralidades leves—, podrá retener un octavo.

c) *Retentio propter impensas* (por causa de gastos). En todos los casos, el marido podrá retener lo gastado en mejoras necesarias* y útiles*; no en las voluptuarias*.

d) *Retentio propter res donatas* (por causa de cosas donadas). Podrá igualmente retener el monto de lo donado —en forma prohibida— durante el matrimonio.

e) *Retentio propter res amotas* (por causa de cosas llevadas). También podrá retener el valor de las cosas que la mujer le hubiera sustraído.

(D) En la época posclásica, el sistema se irá afirmando en el sentido de asegurar a la mujer los bienes dotalés para hacer frente al futuro, una vez disuelto el matrimonio; igualmente, se asegurará el futuro de los hijos.

- * Así, por un lado, la dote será retenida por el marido siempre que la mujer fuera culpable del divorcio o se separara sin motivo. En todos los demás casos, deberá devolverla. También corresponde la devolución, cualquiera sea el caso, si así se hubiera convenido.
- * Si la mujer es *sui iuris*, determinará Justiniano que los bienes dotalés, en caso de muerte de ésta, pasarán a los hijos, gozando el marido un usufructo de ellos.
- * Justiniano suprimirá igualmente la *actio rei uxoriae* otorgando en su lugar una *actio ex stipulatu* —denominación genérica, aplicable aun

en el supuesto de no mediar ninguna *stipulatio*—, más tarde denominada *actio dotis*. Esta *actio ex stipulatu* no será juzgada en forma estricta, sino como un *iudicium bonae-fidei**, razón por la cual su naturaleza es bastante híbrida.

- * El marido conservará el *beneficium competentiae*, pero perderá el derecho a la devolución en tres anualidades de las cosas fungibles: sólo tendrá un plazo de un año.
- * Las *retentiones* desaparecerán como tales. Lo único que disminuirá la dote *ipso iure* serán las mejoras "necesarias", pues las "útiles" deberán ser reclamadas por la *actio negotiorum gestorum*. En cuanto a las *res donatae* y las *res amotae*, las podrá reclamar por la *condictio* o la *reivindicatio*, respectivamente. En cuanto a las demás, se transformarán en contrapartidas credituales que se pueden oponer en forma de compensación*.
- * La mujer tendrá una hipoteca legal general sobre todos los bienes del marido para asegurarse el cumplimiento de la devolución de la dote.

DONACIONES MATRIMONIALES

Donaciones durante el matrimonio. — La regla general es que toda donación efectuada entre marido y mujer es nula. El propósito es tratar de evitar que, a la sombra de los sentimientos, uno de los cónyuges se aproveche de la generosidad del otro, así como también evitar la retribución onerosa del afecto conyugal.

- * Tal como lo dijimos al hablar de donación*, por medio de un *senatusconsulto* de la época de Severo y Caracalla —*oratio Securi*— se determinó que pudieran quedar convalidadas las donaciones entre marido y mujer, si el donante moría sin revocar el negocio.
- * No entraron en la prohibición los pequeños obsequios, ni las donaciones que tenían por objeto el sustento familiar, ni las que no importaban un enriquecimiento estricto: así, la donación de la tumba o los subditos de la mujer para que el marido pudiera organizar juegos públicos.

Donaciones matrimoniales ante nuptias. — Si bien el novio podía regalar a la novia ciertas cosas, generalmente de limitado valor, denominadas *largitates sponsaliciae*, la costumbre de las donaciones *ante nuptias* —generalmente de mayor importancia— será provocada por la influencia oriental y aparecerá en la época posclásica. Se contraponen a las prohibidas, ya que no suceden en el matrimonio, sino antes del matrimonio, y juegan como una contrapartida de la dote.

- * Desde una constitución de Teodosio (año 382 d.C.) aparece la idea de que esas donaciones serán igualmente en el interés de los hijos, luego de disuelto el matrimonio. De este modo, la mujer, no divorciada por su culpa, y, por supuesto, en caso de muerte de su marido, tiene el derecho de conservarla; pero si tiene hijos, les corresponde a éstos dichos bienes, y a la mujer el usufructo de los mismos.

Donaciones propter nuptias. — Justiniano, sobre la base de las donaciones *ante nuptias*, permitirá —incluso durante el matrimonio— hacer donaciones *propter nuptias* (a propósito de las nupcias); éstas funcionarán —al margen de las restantes donaciones matrimoniales, que continuarán prohibidas, como una verdadera contradote, y estarán asimiladas en sus efectos esenciales y restitutorios a las reglas que rigen para la dote.

TUTELA Y CURATELA

Hemos visto en el capítulo referente a la capacidad de las personas que podía existir el caso de una persona con plena capacidad de derecho —un *sui iuris*—, pero con capacidad de hecho disminuida por razones de edad, sexo, enfermedad, etcétera.

Con el fin de brindar protección jurídica a estos incapaces, desde una época muy antigua existían en el Derecho Romano las instituciones de la tutela y de la curatela. Había una tutela para los impúberes y otras para las mujeres.

De las variadas clases de curatelas que hubo, veremos las más importantes: la de los menores de 25 años, la de los pródigos y la de los enfermos mentales.

En un principio, el interés que predominaba era el de la familia agnaticia y tenía en vista el mantenimiento de su patrimonio. En épocas posteriores la atención pasó a centrarse en la protección del incapaz, a través de la defensa de sus bienes.

TUTELA DE LOS IMPUBERES

Paulo atribuye al jurista Servio la siguiente definición de tutela: *Vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data*

99
504 1

98

et permissa (Fuerza y poder sobre una persona libre, dada y permitida por el derecho civil, con el fin de cuidar a quien, por causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo).

En esta definición de la época de Cicerón encontramos vestigios del riguroso derecho primitivo —en la expresión *vis ac potestas*— y un anticipo de la futura orientación de la institución —en la expresión *ad tuendum*.

Esta orientación llevó, por lo demás, a que pudieran ser tutores no sólo, como al principio, los *paterfamilias*, sino también los *filiifamilias* y aun las madres y abuelas, respecto de sus descendientes, siempre que renunciaran a volver a casarse.

TIPOS DE TUTELA

La tutela, según la forma de ser designado el tutor, puede ser testamentaria, legítima o dativa.

Tutela testamentaria. — El tutor era designado por el *paterfamilias* en su testamento. La designación debía recaer, en un principio, en otro *paterfamilias*.

- * Posteriormente, pudieron desempeñar la tutela los *filiifamilias*, latinos y esclavos simultáneamente manumitidos.
- * También, en una época más tardía, el tutor podía ser designado (A) por un testamento dado por la madre, el tío, el abuelo o abuela maternos y (B) aun por un no familiar del incapaz que lo instituyera su heredero. En estos casos el pretor debía confirmar al tutor instituido.
- * Dado que la tutela testamentaria era un *honor**, el designado no podía cederla; podía, en cambio, *abdicare* (rehusar).
- * Llegó a admitirse que el tutor designado en un testamento inválido pudiera, no obstante, ser confirmado por el magistrado.
- * La tutela testamentaria ya aparece mencionada en la legislación de enviral.

Tutela legítima. — En el supuesto de que no existiera tutor testamentario o que el así nombrado rehusara, la ley de las XII tablas ya contemplaba la figura que llenaba este vacío. Esta era la tutela legítima, en la cual el tutor es designado por imperio de la ley. El cargo recaía en el agnado más próximo del incapaz —el hermano, el tío paterno, los hijos del hermano—; en su defecto, uno de los gentiles.

- * En el caso de que los agnados sean impúberes, acceden a la tutela con la pubertad. En el derecho justinianeo se incluyó a los cognados.
- * Recién en el derecho posclásico pudo el designado tutor excusarse sobre la base de causales determinadas; esto proviene del hecho de que la tutela era considerada una carga pública (*munus*; pl. *munera*).
- * Como la tutela legítima es *ipso iure*, no se necesita un nombramiento.

Tutela dativa. — Es la que históricamente surge última. Fue establecida alrededor del 186 a.C. por la *lex Atilia*, en que se estatuyó al pretor urbano, en cooperación con la mayoría de los tribunos de la plebe, como encargado de dar un tutor al incapaz que careciera de él. La idea de la tutela como *munus* se acentúa, así como también el control de los magistrados sobre la gestión del tutor. Como consecuencia de esto no estaba permitido ceder ni rechazar la tutela, pudiendo su ejercicio ser forzado por el magistrado. Existían, empero, ciertas causales de excusación, tales como el desempeño de otras tutelas, tener muchos hijos, residencia alejada, enfermedad, edad avanzada, servicio militar, cargos públicos, etcétera.

- * Posteriormente, alrededor del año 31 a.C., por la *lex Iulia et Titia* se extiende la potestad de nombrar tutores a los gobernadores de provincia. Luego, bajo Claudio, se agregaron los cónsules y, por último, Justiniano incluye al *praefectus urbi*.

ACTUACION DEL TUTOR

Obligaciones antes de entrar en el ejercicio de la tutela. — Probablemente desde Claudio, el tutor debió (A) prestar una garantía (*cautio*), por *stipulatio*, al pupilo de no consumir o disminuir el patrimonio pupilar; (B) establecer ante escribano (*tabularius*) cuál era ese patrimonio. Se dispuso que si el tutor no había inventariado los bienes, valdría en su lugar el inventario hecho por el pupilo bajo juramento.

Actuación durante la tutela. — Hay que diferenciar. (A) Caso en que tutor y pupilo actuaban conjuntamente: el tutor interponía su *auctoritas* *. Esta servía de complemento a la deficiente capacidad del pupilo, quien empero debía ser lo suficientemente evolucionado mentalmente para proferir las expresiones requeridas para el negocio jurídico —en definitiva, ser

PP

*pubertati proximus** (cercano a la pubertad). — (B): Cuando el pupilo era un *infans* —hasta los 7 años— o *infantiae proximus* (cercano a la infancia), el tutor debía actuar por sí solo mediante la *gestio negotiorum* (la gestión de los asuntos). En estos casos el tutor actuaba a nombre propio pero por cuenta del pupilo —es un caso especial de representación* indirecta—; es decir, el tutor se convertía en sujeto activo o pasivo de las obligaciones y titular de los derechos reales, pero con el cargo de posteriormente transpasar el crédito o la deuda y esos derechos reales al patrimonio del pupilo. En razón de esto, el tutor no podía llevar a cabo actos personalísimos, tales como aceptación o renuncia de herencias, nombramiento de *procurator**, *acceptilatio**, etcétera. El número de actos jurídicos que el tutor podía primitivamente realizar era muy grande, dado que actuaba como si fuera el dueño del patrimonio: "*Tutor... domini loco haberi debet*" ("El tutor... debe ser considerado en la condición de dueño"). Podía, por tanto, gravar los bienes del pupilo con *pignus*, enajenarlos, hacer y recibir pagos, colocar el capital en lo que le pareciera conveniente, etcétera.

Estas facultades le fueron siendo restringidas.

(A) En la época preclásica se les prohíbe hacer donaciones importantes.

(B) Por medio de la *oratio Severi* (195 d.C.), se les impide enajenar predios rústicos y suburbanos, extendiéndose posteriormente a los fundos poseídos de buena fe y junto con la prohibición de constituir derechos reales.

(C) Constantino les prohíbe la enajenación de todo tipo de inmuebles, de las cosas muebles de alto valor y de los esclavos.

(D) En el derecho justinianeo aparece regulada la inversión de capitales, los que se debían usar para adquirir inmuebles.

RELACIONES ENTRE TUTOR Y PUPILO

La responsabilidad del tutor en la administración de los bienes del pupilo se fue acrecentando con el correr del tiempo.

(A) Ya en la ley de las XII tablas encontramos dos acciones dirigidas contra los tutores que faltaban a su deber.

1) La *accusatio suspecti tutoris*, que era una acción pública por medio de la cual se lograba la destitución del tutor y se designaba otro.

2) La *actio de rationibus distrahendis*, acción de carácter privado penal por medio de la cual se multaba al tutor con el doble del valor de los bienes defraudados al pupilo.

(B) A fines del período republicano surgió la *actio tutelae*. Esta acción, con un ámbito de aplicación muy elástico, permitía obtener del tutor o de sus herederos una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por su mala gestión y la devolución de los bienes administrados. La sentencia tenía carácter infamante. Naturalmente, el tutor tenía a su vez una *actio tutelae contraria* para reclamar al pupilo los créditos que resultaren a su favor en la gestión de la tutela.

(C) Se concedió, igualmente, al pupilo una acción subsidiaria contra el magistrado que, cuando le incumbía el deber de investigar al tutor que debía nombrar o confirmar, hubiese actuado con evidente imprudencia o negligencia: se lo responsabilizó de los daños sufridos.

TUTELA DE LAS MUJERES

Esta institución, proveniente del antiguo Derecho Romano, en el cual la mujer *sui iuris* carecía de una plena capacidad jurídica, fue decayendo hasta desaparecer en la época de Diocleciano.

CONTENIDO DE LA TUTELA

Dado que la mujer era púber —en caso contrario estaríamos ante la *tutela impuberi*—, las funciones del tutor se limitaban a la *auctoritas**, al contar la pupila con facultades para poder llevar a cabo el acto jurídico. Era, pues, innecesaria la *negotiorum gestio*.

La *auctoritas** era requerida únicamente para negocios *iuris civilis* (del derecho civil), tales como la enajenación de *res Mancipi*, la aceptación de herencias, la *acceptilatio*, la manumisión, etcétera.

100

504 1

99

DELACION DE LA TUTELA

La *tutela mulierum* podía ser de cualquiera de los tres tipos ya estudiados para los impúberes. Para la tutela legítima se llamaba al agnado más próximo; para la *uxor in manu*, el tutor era, en primer lugar, su propio hijo.

Cuando el magistrado designaba al tutor —tutela dativa— lo hacía guiado por las leyes *Atilia* y *Iulia et Titia*, como en el caso de los impúberes.

En el supuesto de la tutela testamentaria era común que el testador concediera a la pupila la *optio tutoris*, por medio de la cual ésta podía elegir la persona de su tutor. La *optio tutoris* fue el primer paso hacia la extinción de la *tutela mulierum*.

Luego, a fines del período preclásico, en el supuesto de que la mujer no pudiera elegir su tutor, podía substituirlo por alguien de su confianza (*fiducia*) por medio de la *coemptio tutelae evitandae causa* que la sujetaba a la *manus* de ese tercero fiduciario: al ser inmediatamente manumitida por él, quedaba de nuevo *sui iuris*, pero sometida a la tutela fiduciaria de aquel tercero.

- * La *lex Iulia et Papia Poppaea*, con objetivos de política demográfica, liberaron de la tutela a quienes tenían el *ius liberorum*, para lo que se exigía tener tres hijos a las ingenuas y cuatro a las libertas.
- * La *auctoritas* del tutor de las mujeres se reduce a una nueva formalidad en el caso de los tutores no legítimos que son constreñidos por el pretor a prestarla.

CURATELA

Esta institución aparece ya en la ley de las XII tablas a propósito del *furiosus* y del pródigo. En el primer supuesto, el poder del *curator* afecta a la persona y los bienes del enfermo mental, mientras que en el segundo la *curatela* se limita al patrimonio heredado por el pródigo.

Alrededor del año 200 a.C. la *lex Plaetoria* dará posteriormente origen a la curatela para los menores de 25 años (*cura minorum*), institución que con el tiempo se irá asimilando a la tutela del impúber.

CURATELA DEL FURIOSUS

No se requería intervención judicial: al producirse el desequilibrio mental surgía, *ipso iure*, la incapacidad y la consecuente necesidad de curatela.

En este caso la *curatela* podía ser legítima o dativa, considerándose que no había una verdadera *curatela* testamentaria ya que una indicación del *pater* en tal sentido era considerada como una mera propuesta al magistrado. Como curadores legítimos debían figurar en primer lugar los agnados más próximos, y en su defecto, los gentiles. La actuación del curador era siempre una *gestio*.

- * Las facultades de aquél sobre los bienes eran muy amplias, ya que se hallaba *domini loco* (en lugar del dueño). La jurisprudencia modificó esto al hacersele extensiva la *Oratio Severi* y al exigirsele, ya en el derecho justiniano, prestar garantía e inventariar los bienes.
- * El derecho clásico consideraba suspendida la curatela durante los intervalos lúcidos del demente.
- * La jurisprudencia asimiló el *mentecaptus* al *furiosus*.

CURATELA DE LOS PRODIGOS

Condición previa a esta curatela es una interdicción que emana del magistrado. La ley de las XII tablas definía al pródigo como la persona con descendencia que malgastase los bienes heredados *ab intestato* de sus ascendientes agnaticios. Similarmente a lo que acontecía con el *furiosus*, la curatela se acordaba a los agnados y gentiles.

I. La primitiva figura se fue ensanchando, abarcando a los que dilapidaban cualquier tipo de fortuna, tuvieran o no hijos. Se admitió también la confirmación del curador testamentario y en su ausencia el magistrado designaba un curador dativo.

II. La incapacidad del pródigo se fue atenuando. Así, en el derecho clásico se le permitieron los actos que podían mejorar su situación patrimonial. Pudieron entonces adir una herencia —superando, así, en capacidad al impúber—, pero no testar, ni siquiera con el consentimiento del curador.

CURATELA DE LOS MENORES DE 25 AÑOS

[Alcanzada la pubertad,] el *sui iuris* era plenamente capaz para realizar cualquier tipo de negocio. Pero, a fines del siglo III a.C., en una sociedad de más frecuentes intercambios, surgió la idea de que los *sui iuris* jóvenes debían ser protegidos de quienes pudieran aprovecharse de su inexperiencia. La *lex Plaetoria* había introducido una acción pública contra los que hubieran, para beneficiarse, usado de artimañas (*circumscriptio*), sin llegar necesariamente a constituir dolo, en los tratos patrimoniales con *minores* (menores de 25 años). El pretor concedió, más tarde, al *minor* una *exceptio legis Plaetoriae* para oponerse a la acción que intentara el acreedor por incumplimiento de una obligación concertada con *circumscriptio* por parte del demandante.

Luego, el pretor comenzó a otorgar la *in integrum restitutio** a los menores que hubieran efectuado un negocio desventajoso. A consecuencia de esto, se vio afectada la actividad comercial de los menores, dado que nadie quería contratar con ellos. Se hizo necesario, entonces, proporcionarles un curador que otorgara su *consensus*, a la manera de una *auctoritas**, al negocio jurídico. El menor podía pedir un curador para cada negocio en particular, y, a partir de la época de Marco Aurelio (siglo II d.C.), pudo pedir un curador con carácter permanente. Como el hecho de tener que contar constantemente con la presencia del curador era muy engorroso, ciertos *minores* llegaron a conseguir del emperador una *venia aetatis* (dispensa de la edad) que eliminaba la necesidad del *curator*. Así, como privilegio especialísimo, se volvía a la misma situación de cualquier púber antes de la sanción de la *lex Plaetoria*.

- * El *consensus* para realizar un negocio no es preciso —a diferencia de la *auctoritas tutoris*— que sea simultáneo a éste y con la presencia física del curador.
- * Por lo demás, el negocio es válido sin *consensus*, dada la capacidad negocial del menor; lo que acontecía en este caso era que en caso de engaño no se tenía ningún tipo de acción porque el pretor la denegaba.
- * Recién en la época posclásica fue exigido el *consensus* para la validez.

CAPITULO XIV

SUCESIONES

Con esta palabra se designan en el derecho clásico los casos de las adquisiciones *per universitatem*, en bloque y simultáneamente, de todos los bienes (*omnia simul bona*) de una persona.

En el derecho justiniano se extiende a los negocios jurídicos por los que se opera una transferencia de dominio de cosas singulares: *successio in singulas res*.

Así, la palabra *successio* tomó, en general, el significado de adquisición derivativa: una persona sucede a otra, es decir, va a ocupar su situación en la titularidad de un derecho o de una universalidad de derechos.

(Se establecieron, así, dos clasificaciones de las sucesiones: (A) sucesiones a título particular y sucesiones a título universal; (B) sucesiones *inter vivos* y sucesiones *mortis causa* (por causa de muerte). Combinando estas dos clasificaciones, se tienen cuatro posibilidades o variantes de sucesión.

a título particular: todo acto translativo de derechos entre personas, por ejemplo, una compra-venta.

a título universal: no existe en el derecho actual, pero sí en el Derecho Romano. Así, en los siguientes casos: a) *bonorum venditio**; b) *adrogación**; c) *conventio in manum** de una *sui iuris*; d) adquisición de la propiedad sobre una persona libre convertida en esclavo por el *ius civile* —como se explica en la pág. 108.

Inter vivos

101 504 1

100

Mortis causa { a título particular: caso del legado.
a título universal: la institución civil de la *hereditas* (herencia) y la pretoriana de la *bonorum possessio* (posesión de los bienes).

Como de las sucesiones *inter vivos* ya se ha tratado, debemos ahora hacerlo a propósito de las *mortis causa*.

SUCESIONES MORTIS CAUSA

El problema del destino y translación de los derechos de que era titular una persona en el momento de su muerte aparece resuelto en los distintos pueblos sobre la base de dos criterios: (A) el de que el ordenamiento jurídico lo regle, atendiendo al interés social y al del grupo familiar; (B) el de facultar a las personas a que en un acto destinado a tener valor jurídico *post mortem* designen las personas que lo sucederán en forma universal —herederos— o particular —legatarios.

El primer criterio es común a todos los pueblos, incluso al romano. Pero éste ha sido absolutamente original en la concepción del segundo, con su exclusiva creación del *testamentum*, el que no sólo se usó para designar a quienes, como herederos, sucederían en la universalidad de sus derechos, sino también, a partir de cierta época, para disponer la sucesión o translación de cosas o derechos singulares a terceros, pero supeditada a la efectiva adquisición de la condición de herederos por parte de los así designados.

En el ordenamiento romano, pues, rigen los dos criterios o sistemas: el de la sucesión testamentaria y el de la intestada, que, como el nombre de esta última lo indica, sólo entra en juego cuando no hay testamento o éste resulta inválido.

En efecto, hay una absoluta incompatibilidad: si hay institución testamentaria válida de ciertas personas como herederos, sólo ellos pueden serlo, aunque las cuotas asignadas expresamente no cubran la totalidad de la herencia. Lo no cubierto no se convertirá en objeto de la sucesión intestada —como ocurre actualmente—, sino que irá a acrecer la porción de los

herederos testamentarios en la proporción de las cuotas asignadas. Es decir, por ejemplo, que si en el testamento solamente se designa heredero a A en tres dozavas partes de la herencia y a B en una dozava parte, no habrá unas ocho dozavas partes de la herencia para ser asignadas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a los parientes más cercanos del difunto, sino que no habrá otros herederos que A por las nueve dozavas y B por la tres dozavas partes de la herencia, respectivamente.

De esta virtud excluyente o exclusiva de la sucesión testamentaria resulta el fundamental principio de *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest* (nadie puede morir en parte testado, en parte intestado).

Esto ocurre, en principio, aun en el régimen de la llamada sucesión legítima o necesaria, por la cual el ordenamiento jurídico había llegado a establecer una cuota mínima —legítima— que necesariamente debía dejarse a ciertos parientes cercanos: si el testamento respetaba la legítima, corrían íntegramente sus disposiciones; si no, podía ser objeto de la *querela inofficiosi testamenti* * (queja de testamento que no cumple con el deber), victoriosa la cual, quedaba nulo el testamento y entraba en juego la sucesión intestada; pero de no prosperar, regía plenamente el testamento.

HISTORIA

El cuadro de las instituciones que giran alrededor de la sucesión *mortis causa* en Roma es muy complejo y ha sufrido más cambios en el tiempo que las otras partes del ordenamiento jurídico. Resulta, pues, muy conveniente destacar previamente algunas de las principales modalidades y tendencias de la evolución de esas instituciones.

I. En los tiempos precívicos y arcaicos —hasta las XII tablas— deben de haber estado en estrechísima relación con la fuerte y política organización de la familia, en la que el *pater familias* es, más que un individualista titular de derechos patri-